

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

มิถุนายน 2553

❖ บทความทั่วไป

- วัตถุประสงค์ในการรับจำนองของธนาคารมีเพื่ออะไร? การที่ธนาคารให้ลูกหนี้ยี่ทำสัญญาประกันชีวิตระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์เป็นธรรมดาหรือไม่?
- กาสิโนกับข้าวหน้า VS รายจ่ายสาธารณะ: ระบบใดดีกว่า? (บทความวิชาการกระจายรายได้ครั้งใหม่)
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่เกิดหลังจึ้นได้เพิ่ม (Immunities of the International Organization)
- ข้อพิพาททางปกครองในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (กรณีศึกษา)
- ความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศ (Immunities of the International Organization)
- มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการค้าเสรีของ WTO
- A Human Right to Health and the Duty to Regulate under International Human Rights Law: With Reference to Health-Care Services
- ความเป็นมาในการเรียนนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
- เรียนกฎหมายอย่างไรให้ได้ดีกับรตินิยม (เรื่องเล่าจากประสบการณ์)

❖ แนะนำกฎหมายใหม่

❖ ปกติกะ:

- ❖ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา
- ❖ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา

วิเคราะห์ข้อสอบ
ชุดวิชา



กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์

คำถาม

เด็กชายสมชายซื้อสร้อยคอทองคำมาหนึ่งเส้น น้ำหนัก 15 กรัม ราคา 12,000 บาท โดยผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ทราบเรื่อง วันรุ่งขึ้นเด็กชายสมชายจึงได้บอกความจริงแก่ผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งขณะนั้นราคาทองคำขึ้นไปเป็น 15,000 บาทต่อน้ำหนัก 15 กรัม ผู้แทนโดยชอบธรรมจึงชมเชยเด็กชายสมชายว่าเก่ง รู้จักซื้อทองคำเก็บไว้จนได้กำไร หนึ่งเดือนต่อมาปรากฏว่าราคาทองคำตกลงเหลือ 10,000 บาทต่อน้ำหนัก 15 กรัม ดังนี้ หากผู้แทนโดยชอบธรรมต้องการบอกเลิกสัญญาซื้อขายดังกล่าวจะทำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด อธิบาย

หลักกฎหมาย

มาตรา 21 ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนการใดๆ ที่ผู้เยาว์ ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นนั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 175 โมฆียะกรรมนั้น บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้

(1) ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้าง ก่อนที่ตน บรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

มาตรา 178 การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระทำได้โดยการแสดงเจตนา แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกำหนดได้แน่นอน

วินิจฉัย

เด็กชายสมชายซื้อสร้อยคอทองคำราคา 12,000 บาท โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมการซื้อขายทองคำจึงตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 21

การที่เด็กชายสมชายไปบอกความจริงกับผู้แทนโดยชอบธรรม และผู้แทนโดยชอบธรรมชมเชยนั้น ไม่เป็นการให้สัตยาบัน เนื่องจากการให้สัตยาบันต้องโดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง คือ คนที่ขายสร้อยคอทองคำให้เด็กชายสมชายตามมาตรา 178

ดังนั้น ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายสมชายจึงสามารถบอกล้างนิติกรรมการซื้อขายทองคำได้ตามมาตรา 175 ตามหลักกฎหมายข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ประเด็นอยู่ที่ว่า การที่เด็กชายสมชายเด็กชายสมชายซื้อสร้อยคอทองคำมาหนึ่งเส้นโดยที่ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายสมชายไม่ทราบเรื่อง นิติกรรมการซื้อสร้อยคอทองคำจึงตกเป็น โมฆียะ และผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายสมชายสามารถบอกล้างนิติกรรมดังกล่าวได้ เนื่องจากการทำนิติกรรมของผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ซึ่งการให้ความยินยอมเช่นนี้จะต้องกระทำก่อนที่ผู้เยาว์ได้ทำนิติกรรมหรือในขณะที่ผู้เยาว์ทำนิติกรรมนั้น ถ้ากระทำในภายหลังจากผู้เยาว์ได้ทำนิติกรรมก็ไม่เป็นการให้ความยินยอม แต่เป็นเรื่องของการให้สัตยาบัน

ประเด็นต่อไปคือ การที่ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายสมชายทราบเรื่องการซื้อสร้อยคอทองคำในภายหลัง และชมเชยเด็กชายสมชายว่าเก่ง รู้จักซื้อทองคำเก็บไว้จนได้กำไรมาก ไม่ใช่ “การให้สัตยาบัน” แก่ นิติกรรมการซื้อสร้อยคอทองคำของเด็กชายสมชาย เนื่องจากการให้สัตยาบันตามมาตรา 178 จะต้องเป็นการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกำหนดได้แน่นอนคือผู้ขายสร้อยคอทองคำดังกล่าวให้เด็กชายสมชายนั่นเอง ไม่ใช่ให้สัตยาบันแก่เด็กชายสมชาย



กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช

คำถาม

ก จ้าง ข ซึ่งเป็นเจ้าของลิงให้เก็บมะพร้าวในสวนของตน เมื่อลิงของ ข เก็บมะพร้าวในสวนของ ก เสร็จแล้ว ข เห็นว่ามีมะพร้าวในสวนของเพื่อนบ้านใกล้เคียงของ ก พอมีมะพร้าวเหลืออยู่บ้าง จึงสั่งให้ลิงเก็บมะพร้าวของเพื่อนบ้านของ ก ด้วย ต่อมาเพื่อนบ้านของ ก ทราบจึงฟ้อง ก ในฐานะนายจ้างให้ร่วมรับผิดชอบ ข ลูกจ้าง เช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมายมาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

มาตรา 425 บัญญัติว่า “นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น”

มาตรา 428 บัญญัติว่า “ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้น แก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ หรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้ หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง”

ข เป็นเจ้าของลิง ข รับจ้าง ก เก็บมะพร้าวโดยใช้ลิงเก็บมะพร้าวในสวนของ ก แต่การที่ ข ได้ใช้ลิงของตนไปเก็บมะพร้าวในสวนของเพื่อนบ้านของ ก เป็นกรณีที่ ข ใช้ลิงของตนเป็นเครื่องมือในการกระทำละเมิดแทนตนโดยจงใจ โดยผิดกฎหมาย ทำให้เพื่อนบ้านของ ก ได้รับความเสียหาย ดังนั้น ข จึงต้องรับผิดชอบเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเองตามมาตรา 420 มิใช่ในฐานะเป็นเจ้าของลิง ตามมาตรา 433

ส่วน นาย ก ซึ่งจ้าง ข เก็บมะพร้าวนั้น ถ้าเป็นการตกลงที่เป็นการจ้างแรงงาน นาย ก อยู่ในฐานะนายจ้าง แต่ นาย ก จะต้องร่วมรับผิดชอบก็ต้องเป็นกรณีที่เป็นการที่ นาย ข ทำในทางการที่จ้างตามมาตรา 425 แต่กรณีนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อทำงานของนายจ้างเสร็จแล้ว จึงไม่ใช่เป็นการกระทำในทางการที่จ้าง นาย ก จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

อนึ่ง หากเป็นการทำสัญญากันเป็นการจ้างทำของ นาย ก ก็อยู่ในฐานะผู้ว่าจ้าง นาย ก จึงไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของ นาย ข เลย ตามมาตรา 428

วิเคราะห์

กรณีนี้เป็นเรื่องนายจ้างและลูกจ้าง และเป็นเรื่องละเมิดของลูกจ้างซึ่งเป็นเจ้าของสัตว์

ประเด็นแรก คือ ลูกจ้างทำละเมิดหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้เห็นได้ว่า ข. ซึ่งเป็นเจ้าของลิงซึ่งเป็นลูกจ้างของ ก. นั้นทำละเมิดเพราะสั่งให้ลิงไปเก็บมะพร้าวของเพื่อนบ้าน ดังนั้น ลูกจ้างทำละเมิดแต่เป็นการทำละเมิดในการกระทำของตนเองตามมาตรา 420 โดยใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการทำละเมิด ซึ่งมีนักศึกษาตอบผิดในประเด็นนี้ว่า ข. รับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้าของสัตว์

ประเด็นที่สอง กรณีให้นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้างหรือไม่นั้น กรณีนี้หากเป็นกรณีที่จ้างแรงงานแล้ว ก. ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบเพราะ ข. ไม่ได้ทำในทางการที่จ้าง

ประเด็นที่สาม หากว่าเป็นกรณีจ้างทำของ นาย ก. ก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างเลย

ส่วนใหญ่ตอบได้ไม่ถูกทั้งหมด เพราะมักตอบว่าลูกจ้างต้องรับผิดชอบเพราะเป็นผู้ทำละเมิดตามมาตรา 420 และต้องรับผิดชอบตามมาตรา 433 ในฐานะเจ้าของสัตว์ด้วย ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะแม้ว่า ข. จะต้องรับผิดชอบนั้นหาก ข. จะต้องรับผิดชอบตามมาตรา 433 ต้องเป็นเรื่องบกพร่องในการเลี้ยงรักษาสัตว์ จึงต้องรับผิดชอบตามมาตรา 433 แต่หากใช้สัตว์เป็นเครื่องมือทำละเมิดนั้นเท่ากับว่า ข. ทำละเมิดด้วยตนเอง แต่ใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ

นักศึกษาต้องระวังในการตอบเพราะมีฉะนั้นจะไม่ได้คะแนน เพราะเข้าใจว่าตอบถูกโดยพยายามให้รับผิดชอบทั้ง 2 มาตรา ซึ่งทำให้ได้คะแนนน้อย



กฎหมายอาญา 1

รองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อคำ

คำถาม

นายกบและนายเสือทะเลาะกันในร้านอาหาร เจ้าของร้านได้เข้ามาห้ามและแยกทั้งสองคนออกจากกัน นายเสือไปโทรศัพท์ที่ตู้โทรศัพท์ที่อยู่หน้าร้านกดไปเพื่อให้ภรรยามารับกลับบ้าน ระหว่างที่นายเสือยืนรอภรรยามารับกลับนั้น นายกบได้หยิบมีดในร้านเข้ามาจะแทงนายเสือเพราะเข้าใจว่านายเสือเรียกเพื่อนมาช่วยทำร้ายตน นายเสือเห็นเข้าจึงหยิบมีดพกเล็ก ๆ ที่ติดมาด้วยแทงนายกบบาดเจ็บ กรณีนี้นายเสือต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไร

แนวตอบ

มาตรา 68 ผู้ใดต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตน หรือของผู้อื่นให้พ้นจากภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด

การกระทำที่เป็นการป้องกันนั้น เป็นสิทธิของผู้ที่ถูกกระทำการที่จะป้องกันสิทธิในชีวิต ทรัพย์สินของตนเอง หรือแม้กระทั่งของผู้อื่น หากผู้หนึ่งหรือผู้อื่นได้ถูกกระทำการประทุษร้าย ซึ่งการประทุษร้ายนั้น เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง ดังนั้นผู้หนึ่งมีอำนาจที่จะป้องกันสิทธิของตนเอง หรือผู้อื่นที่ตกอยู่ในภัยอันตรายนั้นได้ โดยการกระทำนั้นต้องพอสมควรแก่เหตุคือ หากไม่กระทำเช่นนั้นจะไม่พ้นภัย

ดังนั้น การที่นายกบและนายเสือทะเลาะกันในร้านอาหาร โดยเจ้าของร้านได้มาห้าม และแยกย้ายออกจากกันแล้วนั้น การทะเลาะวิวาทได้สิ้นสุดลง การที่นายเสือได้ไปที่ตู้โทรศัพท์ เพื่อให้ภรรยามารับกลับบ้าน นายกบคิดว่านายเสือเรียกเพื่อนมาช่วยจึงหยิบมีดในร้านมาจะแทงนายเสือ นายเสือเมื่อเห็นว่า จะเกิดภัยอันตรายแก่ตนแล้ว จึงได้เอามีดพกเล็ก ๆ ที่ติดมาด้วยแทงนายกบ การกระทำความดังกล่าวจึงเป็นการกระทำเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง จากการทำการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายของนายกบ

นายเสือไม่มีความผิดอาญา เพราะเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ ตามมาตรา 68 ประมวลกฎหมายอาญา



กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายเก่งโกรธนางแก้วภริยาของตนที่ไปสนใจชายอื่น และไม่ยินยอมให้ตนร่วมหลับนอนด้วย วันหนึ่งขณะที่นางแก้วนอนหลับ นายเก่งได้เอาอวัยวะเพศของตนใส่ในปากของนางแก้ว เมื่อนางแก้วรู้สึกตัวก็พยายามดิ้นรนขัดขึ้น แต่นายเก่งได้ใช้กำลังกายบังคับ นางแก้วจึงใช้ฟันกัดอวัยวะเพศของนายเก่งแล้ววิ่งหนีไป

ดังนี้ นายเก่งต้องรับผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 276) บัญญัติว่า "ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขึ้นได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจว่าผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษ..."

การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำ กระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น..."

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายเก่งโกรธนางแก้วภริยาของตนที่ไปสนใจชายอื่นและไม่ยินยอมให้ตนร่วมหลับนอนด้วย จึงได้เอาอวัยวะเพศของตนใส่ในปากของนางแก้วในขณะที่นางแก้วนอนหลับ เมื่อนางแก้วรู้สึกตัวก็พยายามดิ้นรนขัดขึ้น แต่นายเก่งได้ใช้กำลังกายบังคับ การกระทำของนายเก่งถือว่าเป็นนายเก่งได้ข่มขืนกระทำชำเรานางแก้วซึ่งเป็นผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่งการกระทำของนายเก่งเป็นการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของนายเก่งโดยใช้อวัยวะเพศของนายเก่งกระทำกับช่องปากของนางแก้วซึ่งเป็นผู้อื่น อันเป็นความผิดสำเร็จแล้ว แม้นางแก้วจะเป็นภริยาของนายเก่งก็ตาม

ดังนั้น นายเก่งจึงต้องรับผิดทางอาญาฐานข่มขืนกระทำชำเรา ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ต้องการวัดความรู้ของนักศึกษาในความคิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาได้มีการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องการข่มขืนกระทำชำเรา โดยให้การข่มขืนกระทำชำเราที่กระทำกับภรรยาหรือสามีของตนเองก็เป็นความผิด ถ้าผู้ถูกกระทำไม่ยินยอม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมที่บัญญัติว่าการข่มขืนภริยาของตนเองไม่เป็นความผิด จะเป็นความผิดเฉพาะผู้ถูกกระทำต้องเป็นหญิงอื่นอันมิใช่ภริยาตนเท่านั้น นอกจากนี้

ยังมีการแก้ไขลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นการกระทำซ้ำเร้าอีกด้วย โดยแต่เดิมการกระทำที่ถือว่าถึงขึ้นกระทำซ้ำเราต้องเป็นการที่ชายเอาอวัยวะเพศของตนล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิงอย่างน้อยหนึ่งองคุลี ซึ่งถ้ากระทำไม่ถึงขึ้นนั้นก็อาจเป็นเพียงพยายามหรือกระทำอนาจาร แต่ตามกฎหมายใหม่ได้ขยายความหมายของคำว่ากระทำซ้ำเราให้กว้างขึ้น โดยบัญญัติให้การกระทำที่แม้เพียงผู้กระทำใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำ กระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นก็เป็น การกระทำซ้ำเราแล้ว

ในข้อสอบข้อนี้อาจารย์ออกให้ตรงกับตัวบทที่แก้ไขใหม่ เพื่อให้ง่ายและนักศึกษาจะได้ทำได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมาก โดยออกให้สามีเอาอวัยวะเพศใส่ในปากของภริยาโดยภริยาไม่ยินยอม ซึ่งตรงกับตัวบท แต่นักศึกษาหลายคนก็ยังตอบกันผิดอย่างน่าเสียดาย จากการตรวจข้อสอบพบว่านักศึกษายับสับสนระหว่างตัวบทเก่ากับตัวบทใหม่ คือ

1. บางคนยังตอบตัวบทเก่ามาทั้งหมด จะเป็นเพราะนักศึกษาไม่ติดตามว่าได้มีเอกสารการสอนฉบับใหม่ออกใช้แล้ว จึงได้ใช้เอกสารการสอนฉบับเดิมในการดูหนังสือสอบ หรือบางคนใช้เอกสารการสอนใหม่แล้วแต่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ โดยซื้อแต่ประมวลกฎหมายมาอ่านและเป็นประมวลกฎหมายเก่า จึงยังตอบตามกฎหมายเก่า ซึ่งมีผลได้ตอบข้อสอบข้อนี้ผิดไป โดยตอบว่านางแก้วไม่มีความผิด เพราะกระทำกับนางแก้วซึ่งเป็นภริยาตน กฎหมายไม่ถือว่าเป็นความผิด

2. บางคนยกหลักกฎหมายตามกฎหมายใหม่มาตอบถูกต้อง แสดงว่าได้อ่านเอกสารการสอนฉบับใหม่แล้ว แต่อาจจะอ่านหนังสือน้อยไปหรือสับสน จึงตอบว่าตัวบทใช้คำว่า “ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น” คำว่าผู้อื่นหมายถึงคนอื่นที่มีใช้ภริยาตน ดังนั้น นักศึกษากลุ่มนี้ก็ยังตอบว่านางแก้วไม่ผิดเพราะนางแก้วเป็นภริยาตน ซึ่งไม่ถูกต้อง ขอให้ไปอ่านคำอธิบายคำว่าผู้อื่นใหม่

3. นักศึกษาบางคนเอาตัวบทเก่าและตัวบทใหม่มาตอบปะปนกัน จนอาจารย์ผู้ตรวจไม่แน่ใจว่านักศึกษาได้อ่านเอกสารการสอนฉบับเก่าหรือฉบับใหม่กันแน่ โดยยังยกหลักกฎหมายว่า “ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นอันมิใช่ภริยาคน...” ตามตัวบทเก่า และเขียนลักษณะของการกระทำชำเราตามวรรสองของตัวบทใหม่ถูกต้องหมด พุดง่าย ๆ ก็คือ วรรคแรกตอบตามกฎหมายเก่า ส่วนวรรคสองตอบตามกฎหมายใหม่ นักศึกษากลุ่มนี้ก็จะตอบผิดอีก เพราะยังยึดติดกับการข่มขืนหญิงอื่นอันมิใช่ภริยาตน จึงจะมีความผิด

ดังนั้น จึงอยากบอกกับนักศึกษาว่า การเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้นจะต้องหมั่นติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่เสมอว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง เพื่อให้เราไม่ล้าหลัง และติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยในกรณีที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนใหม่ เพราะข้อสอบที่ออกผู้ออกสามารถออกตามเอกสารฉบับใหม่ที่ปรับปรุงแล้วได้ ซึ่งถ้านักศึกษายังใช้เอกสารการสอนฉบับเดิมอยู่ก็จะทำให้นักศึกษาเสียประโยชน์ และขณะนี้สาขาวิชานิติศาสตร์กำลังดำเนินการปรับปรุงเอกสารการสอนอีกหลายชุดวิชา นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วยังสอบไม่ผ่านก็ขอให้ติดตามข่าวสารและซื้อเอกสารการสอนฉบับใหม่ในการสอบครั้งต่อไป ก็จะทำให้นักศึกษาไม่พลาดอีก ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบครั้งต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ



กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์สิน ตัวเงิน

รองศาสตราจารย์เพชร จารุสกุล

ข้อ 1

ค้าทำสัญญากู้เงินแดง 10,000 บาท โดยจำนำแหวน 1 วง ราคา 7,000 บาท เป็นประกันไว้และมีชาวทำสัญญาค้ำประกันหนี้รายนี้ไว้ด้วย ต่อมาแดงคืนแหวนที่จำนำให้แก่ดำไป เมื่อดำผิดนัดไม่ชำระหนี้ แดงมาเรียกให้ชาวรับผิดชอบสัญญาค้ำประกัน ชาวอ้างว่าตนหลุดพ้นความผิดแล้วเพราะแดงคืนแหวนที่จำนำให้แก่ดำไป จงวินิจฉัยว่าข้ออ้างของชาวฟังขึ้นหรือไม่ เพียงใด

ธงคำตอบ

ยกหลักกฎหมายใน ปพพ. มาตรา 697 , 769 (2)

การที่ค้าทำสัญญากู้เงินแดง 10,000 บาท โดยจำนำแหวน 1 วง ราคา 7,000 บาท เป็นประกันไว้แล้วต่อมาแดงคืนแหวนที่ค้าจำนำไว้แก่ดำไป ทำให้จ่านำระงับ ตามมาตรา 769 (2) เป็นการกระทำของเจ้าหนี้ อันเป็นเหตุให้ชาวซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ไม่อาจเข้ารับช่วงได้บางส่วนในสิทธิจำนำ ซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ในขณะทำสัญญาค้ำประกันเพื่อชำระหนี้ ดังนั้น ชาวในฐานะผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นความรับผิดชอบเพียงเท่าที่ตนต้องเสียหาย เพราะเหตุที่จะเข้ารับช่วงสิทธิบังคับจำนำแหวนนั้นไม่ได้ หากชาวได้ชำระหนี้ให้แดงไปแล้ว กล่าวคือ เมื่อดำผิดนัดไม่ชำระหนี้ แดงจะมาเรียกร้องเอาจากชาวได้อีกเพียง 3,000 บาทเท่านั้น ไม่ถึงกับทำให้ชาวหลุดพ้นความรับผิดชอบไปทั้งหมด ข้ออ้างของชาวจึงฟังขึ้นบางส่วน

วิเคราะห์

ตามปัญหาเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้ทำให้ผู้ค้ำประกันไม่สามารถรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่ตนได้ ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิที่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนำ เพราะเป็นความผิดของเจ้าหนี้เอง ทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามมาตรา 697 ที่บัญญัติว่า "ถ้าเพราะการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้เอง เป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันไม่อาจเข้ารับช่วงได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสิทธิก็ดี จำนองก็ดี จำนำก็ดี เพราะบุริมสิทธิอันได้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้แต่ก่อนหรือในขณะทำสัญญาค้ำประกันเพื่อชำระหนี้นั้น ท่านผู้ว่าผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดชอบเพียงเท่าที่ตนต้องเสียหายเพราะการนั้น"

1. นักศึกษาส่วนใหญ่ยกหลักกฎหมายตามมาตรา 697 ไม่ได้ไปตอบเรื่องการใช้สิทธิเบี่ยงบ้ายของผู้ค้ำประกัน ตามมาตรา 688, 689, 690 ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะกรณีนี้โจทย์ให้ข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้ทำให้สิทธิจำนำระงับสิ้นไปตามมาตรา 769 ที่ว่า "อันจำนำยอมระงับสิ้นไป (2) เมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ จึงเป็นเรื่องการกระทำของเจ้าหนี้เป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันไม่อาจรับช่วงได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสิทธิจำนำข้อนี้ นักศึกษาจึงสอบไม่ผ่าน

2. นักศึกษาบางส่วนตอบเรื่องการยกข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันตามมาตรา 694 ที่ว่า "นอกจากข้อต่อสู้ซึ่งผู้ค้ำประกันมีต่อเจ้าหนี้แล้ว ท่านว่าผู้ค้ำประกันยังอาจยกข้อต่อสู้ทั้งหลายซึ่งลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้ได้ด้วย" ซึ่งนักศึกษาอ้างว่ากรณีนี้เมื่อค้ำประกันจำนำให้ผู้จำนำไปแล้ว สัญญาจำนำระงับ ดังนั้น ผู้ค้ำประกันจึงยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ที่ว่าสัญญาจำนำระงับมาต่อสู้เจ้าหนี้ได้ และอ้างมาตรา 698 ที่ว่าอันว่าผู้ค้ำประกันยอมหลุดพ้นจากความรับผิดในขณะเมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไป ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ จึงตอบว่ากรณีนี้เขาจึงหลุดพ้นจากความรับผิดในฐานะผู้ค้ำประกัน ซึ่งตามปัญหานี้เป็นการกระทำของเจ้าหนี้ ทำให้ผู้ค้ำประกันไม่สามารถรับช่วงในสิทธิจำนำได้บางส่วน เมื่อตอบตามมาตรา 694, 698 จึงไม่ถูกต้อง

3. มีนักศึกษาตอบหลักมาตรา 697 ได้ แต่วินิจฉัยไม่ถูกต้อง เพราะกรณีนี้เป็นการกระทำของเจ้าหนี้อันเป็นเหตุให้เขาซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันไม่อาจรับช่วงได้บางส่วนในสิทธิจำนำ คือ 7,000 บาท ขวยอมหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันเพียง 7,000 บาท ตามที่ตนเสียหายเพราะไม่สามารถรับช่วงสิทธิจากเจ้าหนี้ได้ส่วนนี้อีก 3,000 บาท นั้น ขวยังต้องผูกพันตามสัญญาอยู่ นักศึกษาไปตอบว่าหลุดพ้นจากความรับผิดทั้งหมด 10,000 บาท จึงไม่ได้คะแนนเท่าที่ควร



กฎหมายพาณิชย์ ๔

รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี

คำถาม

บริษัทสินเจริญจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีทุนจดทะเบียน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งทุนเป็น ๔๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑๐๐บาท นางศรีมาลา นายชาติ และมิสเตอร์กูมาไก ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น ถือหุ้นคนละ ๑๐,๐๐๐ หุ้น โดยบริษัทมีนายเอกพงศ์ นายโทคม นายตรีศรและนายสีเส้าเป็น กรรมการ ต่อมาคณะกรรมการทั้งสี่ได้ขายตึกแถวติดถนนบอนด์สตรีท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ของบริษัทให้กับ นายห้าแยก ซึ่งราคาซื้อขายตึกแถวดังกล่าวต่ำกว่าราคาตลาดมาก โดยไม่มีเหตุผลสมควรที่จะทำเช่นนั้น นางศรีมาลา ได้มีหนังสือถึงบริษัทสินเจริญจำกัด เพื่อให้ฟ้องกรรมการทั้งสี่คนให้ชดใช้ค่าเสียหายในการขายตึกแถวดังกล่าว ของบริษัท แต่บริษัทสินเจริญจำกัดมีหนังสือถึงนางศรีมาลายืนยันว่าจะไม่ฟ้องคณะกรรมการของบริษัท เพราะ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจขายตึกแถวได้ แม้จะต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ให้ท่านวินิจฉัยว่านางศรีมาลาจะฟ้อง นายเอกพงศ์ นายโทคม นายตรีศรและนายสีเส้า กรรมการ ของบริษัทให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทในฐานะที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

ตาม ปพพ.มาตรา ๑๑๖๘ วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า “ในอันที่จะประกอบกิจการของบริษัทนั้น กรรมการต้องใช้ความเอื้อเพื่อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง”

ปพพ.มาตรา ๑๑๖๙ บัญญัติไว้ว่า “ถ้ากรรมการทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ จะฟ้องร้อง เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนแก่กรรมการก็ได้ หรือในกรณีที่บริษัทไม่ยอมฟ้องร้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดจะเอา คดีนั้นขึ้นมาก็ได้”

ในการจัดกิจการของบริษัทนั้น กรรมการมีหน้าที่ที่จะต้องใช้อุบายเพื่อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขาย ผู้ประกอบการด้วยความระมัดระวังตามปพพ.มาตรา ๑๑๖๘ วรรคแรก จากการที่นายเอกพงศ์ นายโทคม นายตรีศรและนายสีเส้า ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทสินเจริญจำกัดขายตึกแถวต่ำกว่าราคาตลาดมากโดยไม่มี เหตุผลสมควร จึงเป็นการทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท นายเอกพงศ์ นายโทคม นายตรีศรและนายสีเส้า ในฐานะกรรมการจึงต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทฐานไม่ใช้อุบายเพื่อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขาย ผู้ประกอบการด้วยความระมัดระวัง

ซึ่งตามมาตรา ๑๑๖๕ บริษัทสามารถที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการทั้งสี่คนได้ แต่หากบริษัทไม่ได้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด กฎหมายกำหนดให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดสามารถใช้สิทธิในการฟ้องร้องกรรมการเพื่อเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการได้ ดังนั้นนางศรีมาลาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสินเจริญจำกัดจึงสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อกรรมการทั้งสี่คนคือนายเอกพงศ์ นายโทคน นายตรีศรและนายสี่เสา ฐานทำผิดต่อหน้าที่กรรมการที่ไม่ระมัดระวังในการจัดการงานของบริษัทจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหายได้

วิเคราะห์

จากประเด็นที่โจทย์ถามนั้นเป็นประเด็นเรื่องอำนาจของกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทจำกัด ซึ่งมีประเด็นที่นักศึกษาวิเคราะห์ว่าเป็นอำนาจของกรรมการที่สามารถกระทำได้ เพราะถือว่าอยู่ในขอบของวัตถุประสงค์ของบริษัทจึงเป็นอำนาจของกรรมการที่สามารถที่จะขายที่ดินได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย เพราะถือว่าทำในวัตถุประสงค์ แต่พพ.มาตรา ๑๑๖๘ นั้นได้กำหนดไว้ให้กรรมการต้องเอื้อเพื่อสอดส่องกิจการที่กระทำด้วยความระมัดระวัง ดังนั้นการขายที่ดินต่ำกว่าราคามากโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้นจึงถือได้ว่า ขาดความระมัดระวัง อันเป็นกระทำผิดตามมาตรา ๑๑๖๘ และการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท จึงใช้มาตรา ๑๑๖๔ วรรคสาม มาใช้บังคับ โดยกฎหมายกำหนดให้บริษัทฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ถ้าบริษัทไม่ฟ้องจึงให้สิทธินั้นตกมาเป็นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งที่มีสิทธิที่จะฟ้องได้ ซึ่งตามข้อเท็จจริงบริษัทยืนยันว่าไม่ฟ้องกรรมการแน่ จึงเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ นางศรีมาลาจึงมีสิทธิที่จะฟ้องกรรมการทั้งสี่คนได้

ในประเด็นที่กฎหมายให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องได้นั้น กฎหมายให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งแม้เพียงคนเดียวก็สามารถที่จะฟ้องกรรมการได้ หากบริษัทไม่ฟ้อง แต่มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่นำเอาหลักเกณฑ์อื่นมาใช้โดยกำหนดว่าต้องมีผู้ถือจำนวน หนึ่งในสี่ หรือหนึ่งในห้าก็มี รวมกันจึงจะสามารถฟ้องได้ จึงทำให้ตอบว่าต้องไปรวมกับหุ้นส่วนอื่นแล้วจึงจะฟ้องได้ ทำให้คำตอบคลาดเคลื่อนในประเด็นนี้ไปอีกส่วนหนึ่ง

ดังนั้น ในข้อนี้จึงมีประเด็น ที่ผิดพลาดถึงสองประเด็นคือ การเอื้อเพื่อสอดส่องด้วยความระมัดระวัง ซึ่งกรรมการขาดความระมัดระวังในส่วนนี้ไปจึงต้องรับผิดชอบ แม้จะกระทำอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ก็ตาม นั้นประเด็นหนึ่ง ส่วนอีกประเด็นก็คือผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวก็สามารถฟ้องได้เลย ไม่ต้องรวมกันจำนวนหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าตามที่นักศึกษายกมาอ้าง จึงฝากเป็นข้อสังเกตสำหรับนักศึกษา ขอให้วิเคราะห์ให้รอบคอบและจำหลักกฎหมายให้แม่นยำจะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำในครั้งต่อไป



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์

ข้อ 1

นายดีเป็นโจทก์ฟ้องว่า นายมาจำเลยบุกรุกเข้ามาปลูกบ้านในที่ดินพิพาทของนายดีขอให้บังคับนายมา รื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินพิพาท นายมาจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ก่อนวันสืบพยานโจทก์

ก. นายดียื่นคำร้องว่า ที่ดินพิพาทเป็นของนายดำ เพื่อรักษาสงวนสิทธิของนายดำ จึงขอเข้ามาเป็น จำเลยร่วมในคดี

ข. นางเงินยื่นคำร้องว่า นางเงินเช่าที่ดินพิพาทของนายมา จึงขอเข้าเป็นจำเลยร่วมกับนายมา ให้วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นควรสั่งคำร้องของนายดำและนางเงินอย่างไร

แนวตอบ

ป.วิ.พ. มาตรา 57 บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอด

(1) ด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรองคุ้มครอง หรือ บังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกร้อง เกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น

(2) ด้วยความสมัครใจเองเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นโดยยื่นคำร้องขอ ต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา ขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วม หรือเข้าแทนที่คู่ความ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียทีเดียวโดยได้รับความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้นแต่ถ้าแม้ศาลจะได้อนุญาตให้เข้าแทนที่ กันได้ก็ตาม คู่ความฝ่ายนั้นจะต้องผูกพันตนโดยคำพิพากษาของศาลทุกประการเสมือนหนึ่งว่าได้มีการเข้าแทนที่ กันเลย"

มาตรา 58 "ผู้ร้องสอดที่ได้เข้าเป็นคู่ความตามอนุมาตรา (๑) และ (๓) แห่งมาตราก่อนนี้ มีสิทธิ เสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ ซึ่งโดยเฉพาะผู้ร้องสอดอาจนำพยานหลักฐานใหม่มาแสดง คัดค้านเอกสารที่ยื่นไว้ ถ้ามค้านพยานที่ได้สืบมาแล้วและคัดค้านพยานหลักฐานที่ได้สืบไปแล้วก่อนที่ตนได้ ร้องสอด อาจอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และอาจได้รับหรือถูกบังคับ ให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม

ห้ามมิให้ผู้ร้องสอดที่ได้เป็นคู่ความตามอนุมาตรา (2) แห่งมาตราก่อน ใช้สิทธิอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่มีอยู่แก่คู่ความฝ่ายซึ่งตนเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วมในชั้นพิจารณาเมื่อตนร้องสอด และห้ามมิให้ใช้สิทธิเช่นนั้นในทางที่ขัดกับสิทธิของโจทก์หรือจำเลยเดิม และให้ผู้ร้องสอดเสียค่าฤชาธรรมเนียมอันเกิดแต่การที่ร้องสอด แต่ถ้าศาลได้อนุญาตให้เข้าแทนที่โจทก์หรือจำเลยเดิม ผู้ร้องสอดจึงมีฐานะเสมอด้วยคู่ความที่ตนเข้าแทน

วินิจฉัย

ก. ตามคำร้องของนายดำเป็นเรื่องที่นายดำตั้งข้อหาพิพาทเข้ามาเพื่อต่อสู้คดีกับนายดีด้วยความสมัครใจเอง เพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คู่ครองสิทธิของตน ถือได้ว่าเป็นการร้องสอดเข้ามาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1) แม้นายมาจะขาดนัดยื่นคำให้การ นายดำก็ยังมีสิทธิร้องสอดเข้ามาในคดีได้ ดังนั้น ศาลชั้นต้นควรสั่งรับคำร้องของนายดำไว้พิจารณา (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 172/2520)

ข. ตามคำร้องของนางเงิน เป็นเรื่องที่นางเงินขอเข้ามาเป็นจำเลยร่วมด้วยความสมัครใจเอง เพราะตนมีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้น ถือได้ว่าเป็นการร้องสอดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (2) แต่ ป.วิ.พ. มาตรา 58 วรรคสอง บัญญัติห้ามผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยร่วมตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (2) ใช้สิทธินอกจากที่จำเลยเดิมมีอยู่ในขณะร้องสอด เมื่อนายมาจำเลยขาดนัดยื่นให้การ นางเงินผู้ร้องสอดก็ไม่มีสิทธิยื่นคำให้การต่อสู้คดีเพราะเป็นการใช้สิทธินอกเหนือจากที่นายมาจำเลยมีอยู่ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะอนุญาตให้นางเงินผู้ร้องสอดเข้ามาในคดี ดังนั้นศาลชั้นต้นควรสั่งไม่ให้นางเงินเข้ามาเป็นจำเลยร่วม (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 315/2521)

วิเคราะห์

ประเด็นของคำถามมี 4 ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ

1. การที่นายดำยื่นคำร้องว่าที่พิพาทเป็นของตนเป็นการเข้ามาตาม มาตรา 57 อนุมาตราใด ซึ่งคำตอบก็บอกได้ (อย่างโจ่งแจ้ง) ในคำถามนั้นเองที่ว่า "เพื่อรักษาสิทธิของนายดำ" เพียงแต่ไม่ได้ใช้ในตัวบทเท่านั้น ฉะนั้น ถ้านักศึกษาได้อ่านผ่านตามาตรา 57(1) มาบ้าง และเก็บไว้ในสมองบ้างก็จะตอบคำถามประเด็นนี้ได้ (บางคนอ่านแล้วอ่านเลยไม่กล้าจำ ทำแบบ กลัวมหาวิทยาลัยจะเก็บเงินเพิ่มซะงั้น)
2. การเข้ามาตามมาตรา 57(1) มีสิทธิอย่างไร คำตอบก็คือ มีสิทธิตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง "เสมือนฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีใหม่" ฉะนั้น ไม่ต้องสนใจว่า นายมาจะยื่นคำให้การหรือไม่ นายดำก็ยื่นได้ นักศึกษาหลายท่านอ่านหนังสือมา จำได้เลาๆ ว่า เข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่ 3 แต่ไม่รู้ว่าเป็นคู่ความฝ่ายที่ 3 เป็นอันหยั่ง ก็เลยตอบว่า ต้องไปฟ้องคดีใหม่บ้าง ต้องฟ้องแย้งบ้าง ที่หนักที่สุด เขียนว่า "นายดำยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นจำเลยร่วมไม่ได้ ต้องยื่นร้องสอด และจะต้องถูกโต้แย้งสิทธิจากโจทก์และจำเลย จึงจะเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่ 3 ได้" (อาจารย์อุตส่าห์ลอกคำตอบของนักศึกษามาเลยนะเนี่ย) อ่านแล้วก็ปลงนะ กะว่าตรวจข้อสอบเสร็จจะไปบวชชิลล์ 3 เดือน

3. การที่นางเงินร้องสอดเข้ามาในฐานะผู้เช่าที่ดินพิพาท เป็นการร้องสอดเข้ามาตามมาตรา 57 (2) เพราะไม่มีสิทธิของตนเอง ต้องอาศัยสิทธิของนายมา ถ้านายมาแพ้คดี นางเงินก็แพ้ด้วย ถ้านายมาชนะ นางเงินก็ชนะด้วย จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี นักศึกษาหลายท่านวินิจฉัยว่า นางเงินร้องสอดเข้ามาไม่ได้เพราะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ และแย้งไปกว่านั้น นักศึกษาวินิจฉัยว่า แม้นายมาแพ้คดี นางเงินก็ไม่ถูกระทบจากคำพิพากษาเพราะยังไม่ได้คำรื้อถอน อาจารย์อ่านแล้วอึ้งกิมกิ

4. การเข้ามาตามมาตรา 57(2) มีสิทธิตามมาตรา 58 วรสองคือ ห้ามใช้สิทธิอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่มีอยู่แก่คู่ความฝ่ายซึ่งตนเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วมในชั้นพิจารณาเมื่อตนร้องสอด ดังนั้น เมื่อนายมาขาดนัดยื่นคำให้การ นางเงินเข้ามาก็ยื่นคำให้การไม่ได้ เมื่อยื่นไม่ได้ เข้ามาก็ไม่มีประโยชน์ ประเด็นนี้จึงแยกเป็น 2 ประเด็นย่อยคือ เข้าเงื่อนไขมาตรา 57(2) หรือไม่ คำตอบคือเข้าเงื่อนไข และประเด็นย่อยอีกประเด็นคือ ศาลจะให้เข้าหรือไม่ เรื่องนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า ถ้าเข้ามาแล้วทำอะไรไม่ได้ จะให้เข้ามาทำไม แต่เดิมเคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับที่วินิจฉัยแตกต่างกัน คือ ให้เข้ามาบ้าง ไม่ให้เข้ามาบ้าง แต่ปัจจุบัน พิสูจน์แล้วว่า เมื่อเข้ามาแล้วยื่นคำให้การไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ ศาลจึงไม่อนุญาตให้เข้ามาในคดี

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

นอกจากข้อผิดพลาดเรื่อง ไม่ได้อ่านหนังสือในเรื่องที่ออกสอบ เนื่องจากเหตุผลสารพัดที่นักศึกษาสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้ (แม้แต่ “ลูกผมยังเล็ก ต้องเลี้ยงลูก ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ”) นักศึกษาหลายท่านหลงประเด็น มัวประเด็น ดำน้ำ เอลิซังเข้าดู และอื่นๆ อีกมากมาย กลุ่มนี้ต้องเรียกว่ากลุ่มขาดโปรตีน อาจารย์จึงขอมอบไข่ให้ด้วยความรัก และจะรอตรวจข้อสอบตอนสอบซ่อมนะค่ะ

ณ ที่นี้ อาจารย์จะยกเฉพาะประเด็นที่ร่วมกันผิด ไม่ได้ผิดคนเดียว และไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันแต่ใจตรงกัน

1. ข้อที่พบมากที่สุด คือ ยกตัวบทถูก แต่วินิจฉัยไปคนละจักรวาล (ไม่ใช่แค่คนละโลกนะเนี่ย) แสดงว่านักศึกษายังไม่เข้าใจหลักเรื่องร้องสอดเลย แต่โชคดีที่ตอบตัวบทถูกจึงได้คะแนนสำหรับตัวบท อย่างไรก็ตามสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่าน (และท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหลักเรื่องร้องสอด) อาจารย์ขอแนะนำให้หาเวลาว่างกลับไปอ่านหลักมาตรา 57 และ มาตรา 58 ชะหน่อยเพราะเรื่องนี้สำคัญมากโดยเฉพาะท่านที่วางแผนจะสอบ

2. ข้อผิดพลาดเนื่องจากนักศึกษานำชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 และวิธีสบัญญัติ 2 มารวมกันหลายท่านพยายามอย่างมากที่จะอธิบายเรื่อง ขาดนัด (แถมยังอธิบายผิดอีก ต้องซ่อม 2 วิชาแน่เลย) บางท่านยกเรื่องฟ้องแย้ง ลองอ่านข้อความนี้ อ่านเล่นๆ คลายเครียด “ศาลควรสั่งคำร้องของนายดำ ยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดี เป็นคู่ความร่วมมือเพื่อฟ้องแย้งในข้อพิพาท และควรสั่งคำร้องของนางเงิน ร้องขัดทรัพย์” พิมพ์ไม่ผิดไม่ขาด ไม่เกิน เขียนอย่างนี้จริงๆ

3. ข้อผิดพลาดที่เนื่องมาจากการไม่แม่นหลักกฎหมายในอดีตชาติที่สอบผ่านมา (ต้องใช้คำนี้เพราะหลายท่านพยายามเอาหลักเรื่อง “บุกรุก” “สิทธิของผู้เช่า” “ทรัพย์สิน” “เจ้าของร่วม” “กรรมสิทธิ์” ฯลฯ

นอกจากจะเป็นเรื่องนอกประเด็นแล้ว ยังจำหลักผิดอีกต่างหาก จึงไม่แปลกใจที่ไม่ได้คะแนนเลย (โชคดีของนักศึกษาที่อาจารย์ให้คะแนนติดลบไม่ได้)

4. คำตอบนี้ดีมาก ต้องขยาย "ผู้เช่ามีสิทธิเป็นสหปารสบุคคลเท่านั้น ไม่มีสิทธิร้องขอ" นักศึกษาท่านนี้ได้พยายามนำเรื่องร้องขอมาปนกับเรื่องพยาน ปนกันได้ดีจริงๆ อย่างเนียนมาก และนักศึกษาหลายท่าน (จำนวนมากทีเดียว) เนลใจไปพิพากษาคดีเลย ข้อเท็จจริงแค่เนี่ย ท่านพิพากษายกฟ้องก็ได้โดยไม่ต้องนำสืบ น่าเสียดายนักแล้ว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ข้อสอบถามอะไร กฎมาตอบให้ตรงประเด็น อย่าลืมะ ถ้าเป็นคดีพิพากษาหรือสิ่งนอกที่นอกประเด็นไม่ได้ฉันใด อาจารย์ก็ให้คะแนนนอกเรื่องนอกประเด็นไม่ได้ฉันนั้น

นักศึกษาที่ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเปิดอ่านได้ที่ บทเรียน E-Learning ชุดวิชา กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ออนไลน์ **ฟรี** และสามารถอ่านวิธีเข้าใช้บทเรียนได้ที่เว็บไซต์ของสาขาวิชานิติศาสตร์คณะ <http://www.stou.ac.th/schools/sw/home/> หรือ เปิดอ่านที่ <http://www.stou.ac.th/schools/sw/upload/การเข้าบทเรียน.pdf> (ถ้าเปิดใช้ไม่เป็นกรุณาขอคำแนะนำจากลูก หรือ หลานค่ะ) มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้บทเรียน สามารถ Email หาอาจารย์ได้ที่ chaninai@yahoo.com



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายล้มละลาย

อาจารย์จิราพร สุทันกิตระ

ข้อ 1

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้เงินกู้ จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี ศาลนัดชี้สองสถานแต่ก่อนวันนัดชี้สองสถาน โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีจากสารบบความทันที หลังจากนั้นศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 และมีคำพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ แต่ก่อนจำเลยจะยื่นคำแก้อุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ ดังนี้ คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทั้งสองกรณีชอบหรือไม่

แนวตอบ

ป.วิ.พ. มาตรา 175 บัญญัติว่า “ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์อาจถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาล

ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว โจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้น เพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องได้ ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายใต้เงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่

- (1) ห้ามไม่ให้ศาลให้อนุญาต โดยมีได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอด ถ้าหากมีก่อน
- (2) ในกรณีที่โจทก์ถอนคำฟ้อง เนื่องจากมีข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจำเลย ให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้น

ตามอุทาหรณ์ จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้ว จึงได้นัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีทันทีโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องขอถอนฟ้องโดยไม่มีโอกาสคัดค้านหรือไม่คัดค้านในการที่โจทก์ถอนฟ้อง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องไปก่อนที่จะฟังจำเลยที่ 1 เช่นนี้จึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคสอง (1)

การถอนฟ้องมีเฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้น จะถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาไม่ได้ ในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกามีเฉพาะการถอนอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้น ซึ่งให้นำเรื่องการถอนฟ้องมาใช้โดยอนุโลม การถอนอุทธรณ์เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์เท่านั้น แม้ศาลชั้นต้นจะยังไม่ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นก็ไม่มีอำนาจสั่งการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจึงไม่ชอบ

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องการถอนฟ้อง โจทก์ถาม 2 เรื่อง คือ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถอนฟ้อง และอำนาจของศาลแต่ละชั้น ในการตอบข้อสอบอาจแยกประเด็นพิจารณาได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้

1. ความแตกต่างของการถอนฟ้องก่อนจำเลยยื่นคำให้การและการถอนฟ้องภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว ในเรื่องนี้มีหลักเกณฑ์ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดไว้ว่า ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์อาจถอนฟ้องได้ โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาล ดังนั้น ถ้าจำเลยยังไม่ได้ยื่นคำให้การ ศาลอาจอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้โดยไม่ต้องฟังหรือสอบถามจำเลยก่อน และมาตรา 175 วรรคสอง (1) กำหนดว่าในกรณีที่โจทก์ถอนฟ้องภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว ห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง โดยมีได้ฟังจำเลยก่อน ดังนั้นหลังจากที่จำเลยยื่นคำให้การแล้ว ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องโดยไม่ได้สอบถามจำเลยก่อนว่าจะคัดค้านหรือไม่ไม่ได้

2. โจทก์ระบุว่าจำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี และศาลนัดชี้สองสถาน ซึ่งก็หมายความว่าจำเลยได้ยื่นคำให้การแล้ว การวินิจฉัยจึงต้องเป็นไปตามมาตรา 175 วรรคสอง (1) การที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความทันที โดยไม่ได้ฟังจำเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่ จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าว

3. เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วและโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ คดีจึงอยู่ในชั้นอุทธรณ์ แม้ศาลชั้นต้นจะยังไม่ได้ส่งสำนวนไปก็ตาม ศาลอุทธรณ์จึงเป็นศาลที่มีอำนาจสั่งคดี การอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือไม่จึงเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์เท่านั้น

อนึ่ง ตามอุทธรณ์ได้ระบุว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วโจทก์อุทธรณ์ ซึ่งในประเด็นนี้ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วโจทก์จะถอนฟ้องไม่ได้ ดังนั้น การถอนฟ้องจึงมีได้ในศาลชั้นต้นเท่านั้น ส่วนในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาต้องเป็นการถอนอุทธรณ์หรือถอนฎีกา ไม่ใช่ถอนฟ้อง ใดๆ ก็ดี เนื่องจากในเรื่องการถอนอุทธรณ์กฎหมายไม่มีบทบัญญัติเฉพาะ จึงต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยการถอนฟ้อง ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาในศาลชั้นต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ป.วิ.พ. มาตรา 246)

ข้อ 2

คดีแพ่งเรื่องหนึ่ง โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงิน 500,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 400,000 บาท โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ดังนั้นโจทก์และจำเลยจะฎีกาได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง เว้นแต่ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลอุทธรณ์ได้มีความเห็นแย้งหรือผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นก็ดี ศาลอุทธรณ์ก็ดี ได้รับรองไว้หรือรับรองในเวลาตรวจฎีกาว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาไว้ ถ้าไม่มีความเห็นแย้งหรือคำรับรองเช่นนี้ต้องรับอนุญาตให้ฎีกาเป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

วินิจฉัย

ตามปัญหานี้ หนี้ที่ฟ้องมีจำนวน 500,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เป็นเงินแก่โจทก์ 400,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน กรณีโจทก์ฎีกาจึงหมายถึงโจทก์ต้องการให้จำเลยชำระหนี้ครบ 500,000 บาท นั้น หมายถึง โจทก์ยื่นฎีกาเพื่อให้ได้รับชำระหนี้เพิ่มอีก 100,000 บาท ซึ่งถือเป็นจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นศาลฎีกา เมื่อมีจำนวนไม่เกิน 200,000 บาท โจทก์จึงต้องห้ามฎีกาหรือฎีกาไม่ได้

ส่วนการที่จำเลยฎีกานั้นก็หมายความว่าจำเลยไม่ต้องการชำระหนี้ 400,000 บาท ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำนวน 400,000 บาทนี้ถือเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นศาลฎีกา เมื่อมีจำนวนเกิน 200,000 บาท จำเลยย่อมฎีกาได้หรือไม่ต้องห้ามฎีกา

(ตัวอย่างในเอกสารการสอนหน้า 5 - 64 ห้าบรรทัดสุดท้าย)

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มุ่งวัดความรู้เรื่องทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาเป็นสำคัญ จึงไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงอย่างอื่นมาด้วยมากนัก ในการตอบข้อสอบนอกจากจะต้องมีความรู้ในเรื่องทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาตามที่กฎหมายกำหนดแล้วยังต้องสามารถคำนวณทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาได้ถูกต้องด้วย ดังนี้

1. จำนวนทุนทรัพย์เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เพราะป.วิ.พ.มาตรา 248 ได้วางหลักไว้ว่า ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ดังนั้นหากคู่ความต้องการโต้แย้งคำพิพากษา ต้องมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาเกินกว่า 2 แสนบาท จึงจะฎีกาได้ ถ้ามีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ต่ำกว่า 2 แสนบาท หรือ 2 แสนบาทถ้วน ฎีกาไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว

2. ทุนทรัพย์ในแต่ละชั้นศาลอาจไม่เท่ากัน เช่น ทุนทรัพย์ในศาลอุทธรณ์ไม่เท่ากับทุนทรัพย์ในศาลชั้นต้น และทุนทรัพย์ในศาลฎีกาอาจไม่เท่ากับทุนทรัพย์ในศาลอุทธรณ์ก็ได้ มาตรา 248 ใช้คำว่า “ทุนทรัพย์ที่พิพาท” หมายความว่า เป็นทุนทรัพย์ที่คู่ความยังคงขัดแย้งกันอยู่ ด้วยเหตุนี้เมื่อศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแล้ว

แต่คู่ความโต้แย้ง ต่างฝ่ายต่างฎีกา การคำนวณทุนทรัพย์ที่พิพาทกันกันของคู่ความในคดีนั้น จึงต้องคำนวณแยกกัน ทำให้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทของคู่ความอาจไม่เท่ากันได้ เช่นในคดีนี้ ทุนทรัพย์ในศาลชั้นต้นคือ 5 แสนบาท เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 4 แสนบาท จำเลยอุทธรณ์เพราะจำเลยไม่ต้องการชำระเงินให้โจทก์ 4 แสนบาทตามคำพิพากษา ดังนั้น ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ของจำเลย คือ 4 แสนบาท ส่วนโจทก์ก็อุทธรณ์เช่นกันเพื่อให้ศาลพิพากษาให้ตนได้ชำระหนี้เต็มตามที่ฟ้องคือเรียกร้องให้จำเลยชำระอีก 1 แสนบาท ทุนทรัพย์ของโจทก์ในชั้นอุทธรณ์จึงเท่ากับ 1 แสนบาท เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยฎีกา กรณีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาของโจทก์และจำเลยเท่ากับทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ เพราะศาลอุทธรณ์พิพากษายืน เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทของโจทก์ไม่เกิน 2 แสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนจำเลยนั้นเมื่อเกิน 2 แสนบาทจึงไม่ต้องห้ามฎีกาเรื่องทุนทรัพย์



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

อาจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ

ข้อ 1

นายถวิลกับนายพนาเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าโดยไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลา ต่อมานายถวิลเกิดความโลภต้องการได้ไม้เป็นของตนเองไว้แต่เพียงผู้เดียว นายถวิลจึงใช้อาวุธปืนยิงนายพนาจนถึงแก่ความตาย ปรากฏว่าพันตำรวจตรีสุนทรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลา เห็นการกระทำความผิดดังกล่าวจึงรีบติดตามนายถวิลไป แล้วจับกุมนายถวิลได้ที่อำเภอโคกสูง พันตำรวจตรีสุนทรจึงนำนายถวิลไปทำการสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลา เมื่อพันตำรวจตรีสุนทรทำการสอบสวนเสร็จแล้ว จึงได้สรุปสำนวนมีความเห็นควรส่งฟ้องนายถวิลในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น พนักงานอัยการจึงยื่นฟ้องนายถวิลต่อศาลในฐานะความผิดดังกล่าว

ให้วินิจฉัยว่า พันตำรวจตรีสุนทรมีอำนาจสอบสวนหรือไม่ และพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องนายถวิลในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือไม่ อย่างไร

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ มาตรา 19 ในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำความผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่.....

พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้

ในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน

(ก) ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้ว คือ พนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจ

(ข) ถ้าจับผู้ต้องหาไม่ได้ คือ พนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระทำความผิดก่อน อยู่ใน

เขตอำนาจ

มาตรา 120 ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน

จากบทกฎหมายดังกล่าว หมายความว่า ในกรณีความผิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันเกินกว่าหนึ่งท้องที่ เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ไม่แน่ว่าการกระทำความผิดเกิดขึ้นในท้องที่ใดแน่ พนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดนั้น มีอำนาจสอบสวนได้ ถ้าจับผู้ต้องหาได้ในเขตท้องที่ใด ก็ให้พนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับได้ เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน สรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดีต่อไป และเมื่อการสอบสวนได้กระทำไปโดยชอบ

ด้วยกฎหมายแล้ว พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องผู้ต้องหาได้ แต่หากการสอบสวนกระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องถือว่ายังไม่มี การสอบสวนพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องผู้ต้องหา

จากข้อเท็จจริง นายถวิลกับนายพนาเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าโดยไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลา และเพราะความโลภของนายถวิลที่ต้องการไม้ไว้แต่เพียงผู้เดียว จึงใช้อาวุธปืนยิงนายพนาถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 (1) เมื่อข้อเท็จจริงยังฟังไม่ชัดแจ้งว่าเหตุในคดีนี้เกิดในท้องที่ใดแน่ ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลา พนักงานอัยการจึงควรสอบสวนสอบสวนสถานที่ตำรวจภูธรอำเภอหนองปลา ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวน ได้เห็นเหตุการณ์และตามไปจับตัวนายถวิลผู้ต้องหาได้ พนักงานอัยการจึงสามารถมีอำนาจสอบสวนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 วรรคสอง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายถวิลถูกพนักงานอัยการฟ้องสอบสวนสอบสวนสถานที่ตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาจับได้ที่อำเภอโคกสูง ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 วรรคสาม (ก) ระบุว่า พนักงานสอบสวนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน คือ พนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับผู้ต้องหาได้ อยู่ในเขตอำนาจ ดังนั้น พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนี้ คือ พนักงานสอบสวนสถานที่ตำรวจภูธรอำเภอโคกสูง ซึ่งเป็นท้องที่ที่จับนายถวิลผู้ต้องหาได้ อยู่ในเขตอำนาจ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน มิใช่พนักงานสอบสวนสถานที่ตำรวจภูธรอำเภอหนองปลา เมื่อพนักงานอัยการฟ้องสอบสวนสอบสวนสถานที่ตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นผู้สรุปสำนวนและทำความเห็นว่า ควรสั่งฟ้องนายถวิลแล้วส่งสำนวนเพื่อให้พนักงานอัยการพิจารณา ย่อมถือไม่ได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้นโดยชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120

ดังนั้น พนักงานอัยการซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานที่ตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาถึงแม้ว่าจะมีอำนาจสอบสวนได้ แต่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนพนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องนายถวิลในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น (ฎีกาที่ 3466/2547)

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีสองประเด็นที่ต้องตอบ คือ ตำรวจมีอำนาจสอบสวนหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 และพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 และมาตรา 120 โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นคำถามเรื่อง ตำรวจมีอำนาจสอบสวนหรือไม่ เป็นกรณีความผิดที่เกิดเกี่ยวข้องกันเกินกว่าหนึ่งท้องที่ ตามมาตรา 19 นักศึกษาควรอธิบายว่า เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ไม่แน่ชัดว่า การกระทำผิดเกิดขึ้นในท้องที่ใดแน่ ตามมาตรา 19 (1) พนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความผิดนั้นย่อมมีอำนาจสอบสวนได้ เมื่อพนักงานอัยการฟ้องสอบสวนสอบสวนสถานที่ตำรวจภูธรอำเภอหนองปลา ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวน พนักงานอัยการจึงสามารถมีอำนาจสอบสวนได้ ตามมาตรา 19 วรรคสอง

ประการที่สอง ประเด็นคำถามเรื่อง พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องหรือไม่ ตามมาตรา 19 และ มาตรา 120 นักศึกษาต้องอธิบายว่า ในกรณีที่จับผู้ต้องหาได้ในเขตท้องที่ใด ก็ให้พนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ ที่ผู้ต้องหาถูกจับได้ เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสอบสวน ตามมาตรา 19 วรรคสาม (ก) ดังนั้น พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนี้ คือ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกสูง ซึ่งเป็นท้องที่ ที่จับนายถวิลผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน เมื่อพนักงานตำรวจตรีสุนทรสารวัตรสืบสวน สอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นผู้สรุปสำนวนและทำความเข้าใจว่า ควรสั่งฟ้องนายถวิล แล้วส่งสำนวนเพื่อให้พนักงานอัยการพิจารณา ย่อมถือไม่ได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้น โดยชอบ พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องนายถวิลในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ตามมาตรา 120

ประการที่สาม มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยยังสับสนระหว่างพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนกับ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสอบสวน ตามมาตรา 19 ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร กล่าวคือ พนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวน คือ พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้ แต่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสอบสวน มีอำนาจสอบสวนและยังมีหน้าที่สำคัญในการรวบรวม พยานหลักฐาน สรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดี ดังนั้น นักศึกษาจำต้องแยกให้ได้ว่าระหว่างพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสอบสวน

ประการที่สี่ นักศึกษาบางส่วนแม้จะเข้าใจเรื่องพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสอบสวน แต่วินิจฉัยไม่ถูกว่าใครเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสอบสวน ระหว่างกรณีตามมาตรา 19 วรรคสาม (ก) หรือเป็นกรณีตามตามมาตรา 19 วรรคสาม (ข) กล่าวคือ จากข้อเท็จจริงพนักงานตำรวจตรีสุนทร สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลา จับกุมนายถวิลได้ที่อำเภอโคกสูง ในกรณีนี้เป็นการ จับผู้ต้องหาได้แล้ว ตามมาตรา 19 วรรคสาม (ก) มิใช่กรณีพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อน ตามมาตรา 19 วรรคสาม (ข)

ประการที่ห้า นักศึกษาบางส่วนตอบว่า เมื่อยังไม่มีการร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจ สอบสวน จึงเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง เพราะความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดต่อแผ่นดิน แม้ไม่มีผู้ใดร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวน

ประการที่หก นักศึกษาบางส่วนตอบว่า ตามมาตรา 120 พนักงานอัยการฟ้องคดีได้ต้องมีการ สอบสวนในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเสียก่อน เมื่อพนักงานอัยการมิได้สอบสวนจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ซึ่งเป็นการเข้าใจ หลักกฎหมายที่คลาดเคลื่อน เพราะการสอบสวนเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนมิใช่หน้าที่ของพนักงานอัยการ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 เป็นมาตราที่สำคัญ ซึ่งเป็นมาตราที่ต้องการ ทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่องอำนาจสอบสวน นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถจับประเด็นปัญหาได้ถูกต้องว่าคำถามต้องการถามในเรื่องใด



กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

คำถาม

แก้วเช่าบ้านของแหวนอยู่อาศัยโดยตกลงกันด้วยวาจา แต่แก้วไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเลยเป็นเวลาถึงปีเศษ แหวนจึงยื่นคำขาดให้แก้วออกไปจากบ้านเช่นนั้นภายในเวลา 15 วัน มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดี แต่แก้วอ้างว่าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจึงฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่าแหวนจะมีข้อต่อสู้อย่างไร หรือไม่

แนวตอบ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย”

ตามปัญหา แก้วเช่าบ้านแหวนอยู่อาศัยโดยตกลงด้วยวาจา แต่แก้วไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเลยเป็นเวลาถึงปีเศษ แหวนจึงยื่นคำขาดให้แก้วออกไปจากบ้านเช่นนั้นภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดี แต่แก้วอ้างว่าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจึงฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นั้น การฟ้องเพื่อใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ เป็นการใช้สิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 ดังกล่าว มิใช่ฟ้องโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่า จึงไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ประการใด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1714/2546) แหวนเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านดังกล่าวจึงมีอำนาจฟ้องขับไล่แก้วให้ออกไปจากบ้านเช่าดังกล่าวได้โดยไม่มีอายุความ

ฉะนั้น แหวนจึงมีข้อต่อสู้โดยใช้สิทธิติดตามและเอาคืนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 ดังกล่าว

วิเคราะห์

กรณีนี้ นักศึกษามักจะหลงไปตอบว่าเป็นเรื่องเช่าทรัพย์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 แต่ชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาว่าด้วยทรัพย์สิน จึงต้องนำหลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินมาพิจารณา การที่เจ้าของฟ้องเพื่อใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้เป็นการใช้สิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 มิใช่ฟ้องโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่า จึงไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ประการใด



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลาวัญญ์ ถนัดศิลปกุล

คำถาม

บริษัทอเมริกัน เทรเวล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกัน ได้เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท จำกัด ในประเทศไทยดำเนินกิจการ เป็นบริษัทท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 บริษัทดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเป็นอเมริกัน 100% โดยอาศัยสิทธิพิเศษภายใต้สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (Treaty of Amity and Economic Relations) ระหว่างประเทศไทยกับ สหรัฐอเมริกา ที่อนุญาตให้บุคคลและนิติบุคคลของสหรัฐฯ ถือหุ้นกิจการ ในไทยได้ 100% (ขณะที่พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวของไทยกำหนดให้บุคคลและนิติบุคคลของ ต่างประเทศมีสิทธิถือหุ้นกิจการในไทยได้ไม่เกิน 49% มิฉะนั้นจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว) ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งในมาตรา 17 ของ พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติว่า

“มาตรา ๑๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งเป็นนิติบุคคลต้อง

(๑) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบต้องเป็นผู้มี สัญชาติไทยถ้าเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่า ร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัท เกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย”

และภายใต้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ควบคุมการดำเนินธุรกิจนำเที่ยว ผ่านกระบวนการ การออกใบอนุญาต ดังนั้นบริษัทนำเที่ยวทุกบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวถูกกำหนดให้จะต้องปรับ โครงสร้างผู้ถือหุ้นให้มีสัดส่วนการถือครองหุ้นบุคคลธรรมดาระหว่างผู้ถือหุ้นต่างด้าว และ ไทยไม่เกิน ร้อยละ 49:51 ดังนั้นจึงพิจารณาว่าบริษัทอเมริกัน เทรเวล จำกัด จำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ดังกล่าว หรือไม่ เพราะเหตุใด เนื่องจากสนธิสัญญาไมตรีระหว่างประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว จะไม่ออกใบอนุญาตให้บริษัทที่ปฏิบัติผิด มาตรา 17 เพื่อประกอบธุรกิจการนำเที่ยวดังกล่าว จงอธิบาย และยกหลักกฎหมายประกอบการพิจารณา

แนวตอบ

หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

1. รัฐทุกรัฐมีอธิปไตยที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐทุกรัฐมีอำนาจอธิปไตยภายในขอบเขตแห่งเขตแดนของรัฐ เหนือ บุคคล ไม่ว่าคนชาติ หรือ คนต่างด้าว เหนือทรัพย์สิน และ เหตุการณ์ ตลอดจนธุรกรรม ทั้งหลายที่ดำเนินการ และบุคคลทั้งปวงไม่ว่าบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ทั้งคนชาติ และ คนต่างด้าวต่างต้องเคารพกฎหมาย และ อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนั้นๆ
2. อย่างไรก็ตามหากรัฐได้แสดงเจตนาผูกพันตนต่อสนธิสัญญากับรัฐภาคีภายใต้สนธิสัญญา ความตกลงระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระดับทวิภาคี หรือ พหุภาคี รัฐนั้นย่อมจำกัด หรือ ลดอำนาจอธิปไตยลงบางส่วน (Auto limitation) เพื่อที่จะผูกพันตนต่อสนธิสัญญา และต้องอนุวัติการตามสนธิสัญญา ความตกลงระหว่างประเทศ
3. หากรัฐใดได้กระทำการใดที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ พันธกรณีระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรูปของสนธิสัญญา หรือ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอื่นใด คนชาติรัฐอื่นใด โดยการกระทำนั้นเป็นการกระทำของรัฐ ผ่านตัวแทนรัฐไม่ว่าฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ หรือ ตุลาการ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสามารถโอนมาเป็นการกระทำของรัฐได้ (Imputability) รัฐนั้นย่อมต้องรับผิดชอบต่อรัฐอื่น ที่ได้รับความเสียหายจากผลของการกระทำนั้น (State Responsibility)

หลักกฎหมายภายใน

1. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งในมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า

“มาตรา ๑๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งเป็นนิติบุคคลต้อง

(๑) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (ก) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนบุคคลธรรมดา ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยถ้าเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และ กรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย”

2. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

มาตรา ๑๐ บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นการเฉพาะกาล

คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ให้ได้รับยกเว้นจากการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งมาตราต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และให้เป็นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น ซึ่งอาจรวมถึง การให้สิทธิคนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศสัญญาติของคนต่างด้าวนั้นเป็นการต่างตอบแทนด้วย

พันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาไมตรีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา

มาตรา I

บุคคลสัญชาติของแต่ละฝ่าย จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายในของแต่ละภาคีในการที่บุคคลต่างด้าวเหล่านั้นจะเข้ามา จัดตั้งกิจการ และสิ้นสุดการดำเนินกิจการในเขตแดนของแต่ละฝ่าย

มาตรา II

บริษัทที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของแต่ละฝ่ายให้ถือว่ามิใช่สัญชาติของประเทศนั้นและมีสถานภาพทางกฎหมายของอีกฝ่ายหนึ่งนั้น ภายใต้สนธิ สัญญาฉบับนี้ "บริษัท" หมายถึง

- (ก) ตามกฎหมายไทย นิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทย ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลจำกัด หรือ ไม่จำกัด ความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม
- (ข)

มาตรา III

2. ทรัพย์สินของ บุคคลธรรมดา หรือ บริษัท (นิติบุคคล) ของแต่ละฝ่าย รวมทั้งผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการคุ้มครอง และ มีความมั่นคงภายในเขตแดนของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง และจะไม่ถูกเวนคืนยึดทรัพย์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

มาตรา IV

บุคคลธรรมดา และ บริษัท (นิติบุคคล) ของแต่ละฝ่ายจะได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ในการจัดตั้งกิจการทุกรูปแบบ ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจทางการเงิน หรือ ธุรกิจอื่นใด และในการแสวงหาประโยชน์ภายในเขตแดนของรัฐภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง

วินิจฉัย

ประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยในการกำกับ ควบคุม ดูแล การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ตามหลักดินแดน (Territorial Principle) ที่มีอำนาจอธิปไตยเหนือ บุคคล เหนือทรัพย์สิน และ การกระทำใดๆ เหตุการณ์ใดๆ ภายในเขตแดนของรัฐ ดังนั้น แม้ไทยจะมีสนธิสัญญาไมตรีกับสหรัฐอเมริกาที่ให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นอเมริกันให้สามารถจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทย และได้รับการปฏิบัติเยี่ยงชาติ และ เยี่ยงชาติที่ได้รับ ความอนุเคราะห์ยิ่ง อีกทั้งให้สิทธิบริษัทอเมริกันที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีนิติฐานะเป็นนิติบุคคลไทยที่ไม่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว (Art II of the Treaty) แม้จะมีคนอเมริกันถือหุ้น 100% ก็ตาม และ ทำให้บริษัทอเมริกัน

ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ ไม่ต้องถูกจำกัดในเรื่องการดำรงสัดส่วนการถือครองหุ้น 49.51% ระหว่างผู้ถือหุ้นอเมริกัน ต่อผู้ถือหุ้นไทย และไม่ต้องตกอยู่ในบังคับของมาตรา 5, 8, 15, 17 และ 18 ก็ตาม (มาตรา 10 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) แต่ก็ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ และ เงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น ดังนั้นแม้คนต่างด้าวได้รับสิทธิพิเศษตามสนธิสัญญาไมตรี และ รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว แต่ยังคงเป็นไปตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาซึ่งกำหนดให้การจัดตั้ง การเข้ามา และ การดำเนินการทางธุรกิจ และ การสิ้นสุดของนิติบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่รับการลงทุน (Art I of the Treaty)

ดังนั้นบริษัทอเมริกันยังคงตกอยู่ภายใต้กฎหมายไทย ตามมาตรา I, II, III, และ IV ของสนธิสัญญาไมตรี เพราะการที่บริษัทอเมริกัน เมื่อจดทะเบียนในประเทศไทยแล้วไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวก็ตาม ไม่ทำให้นิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยอเมริกัน 100% ซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดยให้ถือว่าเป็นไทยนั้น พ้นไปจากการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ที่ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างคนชาติและคนต่างด้าว ซึ่งบังคับใช้กับทุกๆบริษัทที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ บังคับกับทุกๆนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลไทยที่มีผู้ถือหุ้นไทย หรือนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นชาติอื่นด้วย กฎหมายนี้ บังคับกับทุกๆนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจดังกล่าวกับทุกๆบริษัทที่ต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมนี้ ดังนั้นบริษัทที่มีอเมริกันเป็นเจ้าของย่อมต้องถูกบังคับภายใต้กฎหมายฉบับนี้ด้วย เป็นคนละประเด็นกับเรื่อง การมีสิทธิถือหุ้น 100% แต่ยังมีนิติฐานะที่ไม่เป็นต่างด้าว (A Foreign-owned Thai company) กล่าวคือเป็นบริษัทที่จัดตั้งในไทยที่มีต่างด้าวเป็นเจ้าของ และไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมายย้อนหลัง เนื่องจากกรณีนี้เป็นคนละประเด็นกับการที่บริษัทอเมริกันได้สิทธิในการไม่เป็นต่างด้าว แม้ถือหุ้นโดยชาวอเมริกัน 100% เพราะกฎหมายที่ออกใหม่ภายหลังนี้ ไม่ได้ไปกระทบต่อสิทธิ หรือ สบล้างสิทธิ ในการไม่ต้องเป็นนิติบุคคลต่างด้าวของบริษัทอเมริกันที่มีผู้ถือหุ้น อเมริกัน 100% ไม่ เพราะกฎหมายใหม่ที่ออกมานี้ มีขึ้นเพื่อควบคุมบริษัทที่จะประกอบธุรกิจการนำเที่ยว และ มัคคุเทศก์ อันเป็นเงื่อนไขของการจะประกอบธุรกิจนี้ และใช้บังคับกับทุกๆนิติบุคคล ดังนั้น บริษัทอเมริกันที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดย่อมต้องตกอยู่ใต้กฎหมายไทย ดังกล่าวด้วย หากจะประกอบธุรกิจนี้ และตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวนี้ ได้บัญญัติในเรื่องสัญชาติของบุคคลธรรมดา ที่ถือหุ้น หรือ มีหุ้นส่วนในนิติบุคคลต้องมีสัญชาติไทยในอัตราที่กำหนด

การให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หมายความว่าถึงแม้คนต่างชาติจะไม่เป็นคนชาติ แต่รัฐก็จะให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ แต่คนต่างด้าวก็ยังเป็นต่างด้าวอยู่ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว บัญญัติไว้เฉพาะกรณีของการเป็น หรือ ไม่เป็นต่างด้าว แต่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดสัญชาติ ของนิติบุคคลไว้ (Criteria for judging Nationality of Juristic Person) ดังนั้น ภายใต้สนธิสัญญาไมตรี ที่ให้สิทธิ คนอเมริกัน ที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย แม้มีผู้ถือหุ้น 100% เป็น อเมริกันก็ไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นต่างด้าวและให้ถือว่าเป็นนิติบุคคลไทย แต่ไม่ได้หมายความว่า นิติบุคคลนั้นถือหุ้นโดยบุคคลสัญชาติไทย การให้สิทธิพิเศษในกรณีนี้ คือ การให้การปฏิบัติเยี่ยงชาติ กล่าวคือ ถึงแม้นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นอเมริกันทั้ง 100% แต่ก็ให้ถือปฏิบัติว่านิติบุคคลนั้น เป็นเยี่ยงคนชาติ (ไม่เป็นไทยแต่ให้ถือว่าเป็นไทย และ ปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงเขาเป็นไทย)

หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ จะไม่บังคับกับข้อสงวน หรือ ธุรกิจที่เป็นธุรกิจต้องห้าม ไม่เปิดให้คนต่างด้าวประกอบอาชีพ หรือ ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าผู้ถือหุ้นต้องเป็นบุคคล สัญชาติไทย เมื่อมีกฎหมายพิเศษที่กำหนดว่าธุรกิจใดเป็นอาชีพสงวนก็จะเป็นข้อยกเว้นของการที่ไม่ต้องให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ดังนั้นพระราชบัญญัติใดที่กำหนดไว้เป็นพิเศษให้ผู้ถือหุ้นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย จึงต้องเป็นไปตามนั้น เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติยกเว้นไว้เป็นกรณีๆ

ดังนั้นกฎหมายที่ออกมาภายหลังที่กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้นให้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยจึงไม่ได้ขัดหรือแย้งกับ สนธิสัญญาไมตรี เพราะสนธิสัญญาไมตรี เป็นเรื่องการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ไม่ใช่เรื่องการยกเว้นคุณสมบัติว่าให้สามารถไม่ต้องมีบุคคลธรรมดาผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในกิจการเฉพาะที่กฎหมายกำหนดยกเว้นไว้โดยเฉพาะดังกล่าว จึงเป็นคนละกรณีกัน อีกทั้งสนธิสัญญาไมตรีได้ยกเว้นกรณีอาชีพสงวนไว้แล้วว่าไม่ต้องให้ National Treatment เพราะเป็น Specific exception ในเรื่องอาชีพสงวน ที่ยังเป็นอธิปไตยของรัฐที่รับการลงทุน (Host Country) ที่จะมี Right to regulate สิทธิในการกำกับดูแล และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาตินั้น ตกอยู่ภายใต้ ข้อยกเว้น ซึ่งมีทั้ง General exception กับ specific exception การปฏิบัติต่อคนต่างด้าวเยี่ยงคนชาติ เป็นเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัติ ระหว่างคนชาติกับคนต่างด้าว เพื่อให้ความเป็นธรรมในการแข่งขัน แต่ ธุรกิจใดที่เป็นข้อสงวน ไม่ต้องให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแก่คนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิดังกล่าว เว้นแต่มีกฎหมายยกเว้นอีกที่ เป็นกรณีๆ ไป

อีกประการ การปฏิบัติเยี่ยงชาตินั้น ต้องอยู่ภายใต้ "สถานการณ์เดียวกัน" "The like Circumstances" หรือ หากบังคับกับการค้าสินค้าต้องเป็นสินค้าเดียวกัน "The like product" การให้การปฏิบัติเยี่ยงชาติจึงไม่ใช่เป็นการให้ทั่วไประหว่างต่างด้าวต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนคนชาติทุกประการแต่ละกรณีเหมือนกัน หรือภายใต้สถานการณ์เดียวกัน

สรุป

บริษัทที่มีอเมริกันเป็นผู้ถือหุ้น 100% หากจะประกอบธุรกิจ การนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจสงวนและมีกฎหมายพิเศษกำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นในบริษัทต้องเป็นคนชาติมากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็น 49:51% ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เพราะ พรบฉบับนี้ไม่ได้บังคับเฉพาะกับนิติบุคคลที่มีต่างด้าวเป็นเจ้าของ หาก แต่บังคับกับทุกๆนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลไทยที่มีต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมอยู่ด้วย เมื่อบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นอเมริกันได้รับการปฏิบัติเยี่ยงชาติก็ต้องปฏิบัติตามด้วย เพราะ พรบ ฉบับนี้ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด เว้นแต่ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ออกกฎหมายยกเว้นกรณีของนักลงทุนสหรัฐอเมริกาไว้อีกชั้นหนึ่ง ให้เป็นไปตามสนธิสัญญาไมตรี ซึ่งในกรณีนี้ก็จะขัดแย้งกับหลัก การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most - Favored - Nation Treatment - MFN)

วิเคราะห์

สรุปปัญหาที่นักศึกษาตอบข้อสอบไม่ได้ คือ ปัญหาในการอ่านหนังสือ การไม่เข้าใจ ไม่สามารถวิเคราะห์ หรือ ตีความได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาไม่เข้าใจเรื่อง การปฏิบัติ (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ (National Treatment) กับการต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลสัญชาติไทย สองสิ่งนี้ไม่เหมือนกัน นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบข้อสอบผิดในส่วนนี้

คำถาม

นางมิกิ คนญี่ปุ่นได้สมรสกับนายธงชัย คนไทย และขอถือสัญชาติไทยตามสามี โดยไม่ได้สละสัญชาติญี่ปุ่น แต่ต่อมานางมิกิได้หย่าร้างกับนายธงชัย แต่ยังคงอยู่อาศัยในประเทศไทย จึงไปขอซื้อที่ดินจากนายแดง และ นายแดง ตกลงขาย ที่นา 10 ไร่ ให้แก่ นางมิกิ ทั้งคู่ได้เดินทางไปทำสัญญาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนังสือ และระบุไว้ในสัญญาว่าหากเกิดกรณีพิพาทระหว่างคู่สัญญาให้ใช้กฎหมายญี่ปุ่นบังคับกับคดี หากตามกฎหมายญี่ปุ่น แบบของสัญญาซื้อขายที่ดินต้องทำหนังสือสัญญาเป็นหนังสือแต่ไม่ต้องจดทะเบียน ต่อมา นางมิกิ ไม่ชำระค่าที่ดินแก่นายแดง และ ไม่ยอมรับโอนที่ดินจากนายแดง เนื่องจากสืบทราบมาว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวจะถูกรัฐบาลเวนคืนเพื่อสร้างถนน นายแดง จึงฟ้องร้องนางมิกิ ที่ศาลแพ่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามสัญญา และอ้างกฎหมายญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศที่ทำสัญญาให้นำมาปรับใช้กับคดี อีกทั้งคู่สัญญาได้แสดงเจตนาให้ใช้กฎหมายญี่ปุ่นบังคับกับคดีด้วย หากท่านเป็นผู้พิพากษาในคดีนี้ ท่านจะ พิจารณาพิพากษาอย่างไร

หลักกฎหมาย

1. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไข พ.ศ. 2551

มาตรา 9 หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทยให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย มาตรา 16 ได้กำหนดว่า "ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์สินตั้งอยู่บังคับแก่สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์"

ในกรณีของอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่จะใช้บังคับกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่

1. การพิจารณาว่าทรัพย์สินใดเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์
2. ทรัพย์สินสิทธิ หรือ กรรมสิทธิ์อื่นใดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
3. การสิ้นสุดแห่งทรัพย์สินสิทธิแห่งอสังหาริมทรัพย์ หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น
4. การโอนกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

5. สิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
6. เครื่องอุปกรณ์ ส่วนควบที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น
7. แบบแห่งสัญญา นิติกรรม หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
8. ผลของคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
9. ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
10. สำระสำคัญและผลของสัญญาก่อนสมรสในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
11. อำนาจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของผู้เยาว์
12. มรดกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4

ในกรณีที่มีปัญหาการขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล เกณฑ์ในการพิจารณาเขตอำนาจของศาลไทย ในคดีที่พัวพันกับต่างประเทศนั้นได้มีการกำหนดเขตอำนาจศาลในคดีแพ่ง และ พยานิษย์ที่พัวพันกับองค์ประกอบต่างชาติโดย จะถือจุดเกาะเกี่ยวที่ใกล้ชิดกับรัฐเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ศาลภายในควรมีเขตอำนาจศาลเหนือคดีที่รัฐนั้นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออำนาจของรัฐนั้นสามารถเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ ในกรณีเขตอำนาจศาลเหนือคดีแพ่งและพยานิษย์นั้นเกณฑ์ที่นิยมกันทั่วไปก็ได้แก่ ภูมิลำเนาของจำเลย สถานที่ตั้งแห่งทรัพย์สิน สัญชาติของโจทก์ ภูมิลำเนาโจทก์ ในกรณีนิติบุคคล ก็ให้ถือเอาสถานที่ตั้งแห่งใหญ่กับเขตอำนาจศาล หลักเกณฑ์เหล่านี้พิจารณาระดับความใกล้ชิด หรือจุดเกาะเกี่ยวที่ใกล้ชิดอันจะมีผลต่อการรับรอง และ บังคับการตามคำพิพากษาของศาลนั้นๆ

ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับภูมิลำเนาจำเลยนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยในปัจจุบันได้บัญญัติถึงเรื่องเขตอำนาจศาลไว้ในมาตรา 4 ว่า

“เว้นแต่จะมีบัญญัติเป็นอย่างอื่น

- (1) คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือ ต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่
- (2) คำร้องขอให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล”

การที่กฎหมายบัญญัติถือเอาภูมิลำเนาของจำเลยเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดเขตอำนาจศาลก็เพราะเหตุว่าวัตถุประสงค์ในการนำคดีสู่ศาลเพื่อให้ศาลตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทนั้นๆ และเมื่อศาลตัดสินชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้วก็ต้องมีการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล ดังนั้นในกรณีคดีเกี่ยวกับหนี้เนื้อบุคคล หากจำเลยไม่ปรากฏอยู่ภายในรัฐที่ศาลทำการพิจารณาพิพากษาคดีอยู่ การบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาก็ย่อมเป็นไปได้ยาก

4. ประมวลกฎหมายแพ่ง พยานิษย์ มาตรา 456 วรรค 1 ซึ่งบัญญัติว่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้รั้งหน้าว่าเป็นโมฆะ.....

มาตรา 152 การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ

วินิจฉัย

นางมิกิ หญิงชาวญี่ปุ่น เมื่อได้สมรสกับชายไทยและขอมีสัญชาติไทยตามสามีแล้วย่อมได้สัญชาติไทย แม้ต่อมา จะหย่าร้างไปแล้วแต่ไม่ได้ขอสละสัญชาติไทย ก็ยังคงมีสัญชาติไทยอยู่ และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย เมื่อนางมิกิตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดิน อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ ถึงแม้จะไปทำสัญญาที่ประเทศญี่ปุ่นและตกลง ให้ใช้กฎหมายญี่ปุ่นบังคับก็ตาม แต่ เมื่อมีข้อพิพาทด้วยเรื่องสัญญาซื้อขาย เกี่ยวกับแบบของนิติกรรม ตาม พระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน กำหนดให้ใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับแบบ ของนิติกรรม เนื่องจาก แบบของนิติกรรมในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นแบบบังคับเด็ดขาดไม่อาจจะเลือกทำ นิติกรรมในรูปแบบอื่นที่ฝ่าฝืนมาตรา 456 วรรค 1 ได้ ดังนั้น สัญญาซื้อขาย จึงเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น เพราะ คู่สัญญาตกลงเป็นเด็ดขาดที่จะให้เป็นไปตามแบบของกฎหมายญี่ปุ่นที่ไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน แต่เพียงทำเป็นหนังสือเท่านั้น เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 456 วรรค 1 ดังกล่าว

ในส่วนการฟ้องร้องที่ศาลแพ่งซึ่งมีเขตอำนาจศาล ตามวิพ มาตรา 4 ซึ่งโจทก์ได้เสนอคำฟ้องต่อศาล ที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้นสามารถกระทำได้ แต่การจะให้บังคับตามแบบของนิติกรรมที่ทำในประเทศญี่ปุ่น ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายไทยนั้นไม่สามารถกระทำได้ เพราะศาลไทยต้องบังคับตามกฎหมายของประเทศที่อสังหาริมทรัพย์ นั้นตั้งอยู่

และกรณีนี้สัญญาซื้อขายที่ดินที่เป็นโมฆะนี้ แม้จะได้ทำเป็นหนังสือนั้น เมื่อโมฆะในฐานะสัญญาซื้อขาย เสร็จเด็ดขาดแต่ก็ไม่สามารถเข้าลักษณะเป็นสัญญาอื่น กล่าวคือ สัญญาจะซื้อ จะขายได้เพราะคู่สัญญาไม่มีเจตนา มาแต่แรกว่าจะให้สมบูรณ์เป็นเช่นนั้นด้วยไม่ว่าต้องทำเป็นหนังสือ จึงไม่อาจจะบังคับ ให้ปฏิบัติตามสัญญาใน ฐานะบุคคลสิทธิได้

สรุป

1. คดีนี้ศาลรับฟ้องได้เนื่องจากศาลแพ่งมีเขตอำนาจศาลที่จะพิจารณาคดี
2. ศาลไม่สามารถปรับใช้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมาบังคับกับคดีได้เพราะการพิพาทด้วย เรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
3. ศาลต้องปรับใช้กฎหมายไทย และ พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายภายในของไทยเกี่ยวกับแบบของ นิติกรรม การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อคู่สัญญา ไม่ได้ทำตามแบบแห่งนิติกรรมสัญญา สัญญาซื้อขายที่ดินย่อมเป็นโมฆะ และไม่เป็นสัญญาจะซื้อจะขาย
4. ศาลจะพิพากษายกฟ้องโจทก์

วิเคราะห์

นักศึกษาตอบข้อสอบข้อนี้ไม่ได้เนื่องจาก นักศึกษาไม่เข้าใจเรื่อง "กฎหมายขัดกัน" นักศึกษาเข้าใจว่า กฎหมายขัดกันคือ กฎหมายประเทศนี้แตกต่างจากกฎหมายอีกประเทศหนึ่ง ซึ่ง นักศึกษาต้องทำความเข้าใจ สองคำนี้ คือ

"กฎหมายขัดแย้งกัน" กับ "กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย"

"กฎหมายขัดแย้งกัน" คือกฎหมายแตกต่างกัน แต่ "กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย" เป็นกฎหมาย ที่ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย เป็นเครื่องมือในการหากฎหมาย มาบังคับใช้ในกรณีที่ มีข้อพิพาทที่มี องค์ประกอบต่างชาติ

เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจสองคำนี้ จึงไม่สามารถปรับหลักกฎหมายได้ เพราะการปรับหลักกฎหมายตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายนั้น จะต้องให้ลักษณะกฎหมายแก้ไขจริงเสียก่อน เมื่อให้ลักษณะ ของกฎหมายแก้ไขจริงแล้วจึงจะสามารถ ทราบว่าพิพาทกันด้วยเรื่องใดที่จะต้องใช้กฎหมายของประเทศใด มาบังคับกับคดี จึงไม่ใช่เรื่องที่ว่ากฎหมายญี่ปุ่นขัดกับกฎหมายไทย เมื่อคู่สัญญาให้ใช้กฎหมายญี่ปุ่นจึงใช้กฎหมาย ญี่ปุ่น ทันที หากได้ นักศึกษาต้องพิจารณาก่อนว่าคู่กรณีพิพาทกันด้วยเรื่องอะไร ต้องให้ลักษณะกฎหมายแก้ไขจริงเสียก่อน เมื่อหาได้จึงพิจารณาว่า พรบ. ขัดกันให้ใช้กฎหมายของประเทศใด

นักศึกษาไม่เข้าใจว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หมายถึงอะไร ข้อพิพาทเกี่ยวกับมูลสัญญา หมายความว่าอย่างไร ข้อพิพาทเกี่ยวกับละเมิด คืออะไร เมื่อวิเคราะห์ไม่ได้ก็ปรับหลักกฎหมายไม่ได้ ในกรณีนี้ เป็นการพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพราะพิพาทกันด้วยเรื่องแบบของนิติกรรม ซึ่งพรบ. กฎหมายขัดกันให้ ถือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ คือ กฎหมายไทย

นักศึกษาไม่ทราบว่า แบบของนิติกรรมแบบเด็ดขาด เช่น การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องทำเป็น หนังสือและจดทะเบียนนั้น ไม่อาจจะเลือกใช้กฎหมายอื่นได้

นักศึกษาไม่ทราบว่า เขตอำนาจรัฐ กับเขตอำนาจศาล ต่างกันอย่างไร คดีเมืองกับคดีบุคคลต่างกัน อย่างไร

นักศึกษา ไม่ทราบว่า การพิจารณาเขตอำนาจศาลตามปวิพ ต่างจากการยอมรับ และ บังคับตาม คำพิพากษาศาลต่างประเทศอย่างไร

นักศึกษาจำนวนมากลอกเลียนเฉลยข้อสอบเก่า เรื่อง เช่าตึกที่สิงคโปร์ อันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับ มูลสัญญา ซึ่งเป็น บุคคลสิทธิ มาตอบในข้อสอบเทอมนี้ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นเดียวกัน เพราะข้อสอบใหม่เป็นเรื่อง แบบของสัญญา ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นักศึกษา ต้องพิจารณา อย่างน้อยที่สุดต้องรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องบุคคลสิทธิ อะไรเป็นทรัพย์สินสิทธิ เสียก่อน และอะไรเป็นแบบของนิติกรรมสัญญา

นอกจากนั้น นักศึกษาไม่ทราบเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทยของหญิงต่างด้าวตามคู่สมรสชายไทยนั้น เมื่อได้ขอมีสัญชาติไทยแล้ว แม้การสมรสสิ้นสุดลง ก็ไม่สูญเสียสัญชาติไทย ไม่ว่าสามีเสียชีวิต หรือ หย่าร้างกันไป หญิงต่างด้าวที่ได้สัญชาติไทยแล้วก็ยังคงมีสัญชาติไทยอยู่

ข้อ 3. "การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ เป็นการโจมตีของจักรวรรดิญี่ปุ่นต่อฝ่ายกองทัพอเมริกา โดยการ โจมตีเกิดขึ้นที่ อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ มลรัฐฮาวาย ในสหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) ในการโจมตีนี้สร้างความเสียหายแก่ฝ่ายกองทัพสหรัฐอเมริกามาก โดยเรือสงครามสูญเสีย 12 ลำ เครื่องบิน 188 ลำ ทหารอเมริกันเสียชีวิต 2,403 คน และ ประชาชน 68 คน" การกระทำดังกล่าว ถือว่าผิดหลักกฎหมาย ระหว่างประเทศในเรื่องใด หรือ ไม่ เพราะเหตุใด และ จงอธิบายหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่อง

ดังกล่าว เกี่ยวกับกฎหมายการจำกัดสิทธิในการใช้กำลังทางทหาร (Jus ad Bellum) และ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติการทางทหาร (Jus in Bello)

แนวตอบ

Jus ad bellum เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภาคสงคราม (Law of War) ที่ใช้บังคับต่อรัฐซึ่งกำหนดหลักการต่างๆ ว่าเมื่อไรรัฐจะใช้กำลังได้และเมื่อไรจะใช้กำลังมิได้ แตกต่างจาก **Jus in bello** ตรงที่ Jus in bello ก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภาคสงครามเช่นกัน แต่เป็นส่วนที่ว่าด้วย "กฎเกณฑ์ในการทำสงคราม" ซึ่งใช้บังคับต่อพลรบและพลเรือนโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น การห้ามโจมตีเป้าหมายพลเรือน หน่วยกาชาดและหน่วยวงเดือนจิกสีแดง ฯลฯ ห้ามใช้อาวุธเพลิง ห้ามใช้ทุ่นระเบิดบางประเภทหรืออาวุธที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บทรมานทุกข์ทรมานมากเกินไป ห้ามมิให้พลเรือนเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมสงคราม เป็นต้น

หลักกฎหมาย Jus ad bellum

สาระสำคัญของ Jus ad bellum แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ หลักการที่ห้ามมิให้ใช้กำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและข้อยกเว้นต่างๆ ของหลักการนั้น

1. หลักการที่ห้ามมิให้ใช้กำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เป้าหมายของข้อห้ามดังกล่าวคือ รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในฐานะที่เป็นภาคีของกฎบัตรสหประชาชาติ ตลอดจนรัฐอื่นๆ ซึ่งถึงแม้จะมีได้เป็นภาคี ก็ต้องถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านั้น ซึ่งนานาชาติถือว่าได้กลายเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปสำหรับทุกๆ รัฐไปแล้ว

2. ลักษณะของการใช้กำลังที่ต้องห้าม

ส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าการใช้กำลังที่ต้องห้ามตามมาตรา 2 วรรค 4 หมายถึงการใช้กำลังทางทหารเท่านั้น เนื่องมาจากปรัชญาของกฎบัตรฯ เกี่ยวกับการดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงจะเน้นอยู่ที่การป้องกันและปราบปรามการใช้กำลังทางทหารที่มีผลกระทบต่อสันติภาพ ยิ่งกว่านั้นข้อสมมติเกี่ยวกับคำนิยามของการรุกรานก็กล่าวถึงเฉพาะการใช้กำลังทางทหารทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่านั้น ทั้งนี้ การใช้กำลังทางทหารที่เข้าข่ายของการต้องห้ามดังกล่าวมิได้ขึ้นอยู่กับว่าได้มีการประกาศสงครามหรือมีการรับรองสถานะสงครามของรัฐที่เป็นฝ่ายในการพิพาทกันนั้นหรือไม่แต่อย่างใด ดังนั้นการสู้รบและการใช้กำลังทางทหารใดที่อยู่ในเกณฑ์ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นการใช้กำลังทางทหารที่ต้องห้ามตามมาตรา 2 วรรค 4 ก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งนั้น ทั้งนี้ถึงแม้รัฐที่เป็นฝ่ายในการสู้รบจะได้ประกาศสงครามหรือมิได้รับรองสถานะสงครามก็ตาม

3. รูปแบบและระดับของความรุนแรงของการใช้กำลังทางทหาร

การใช้กำลังทางทหารที่ผิดกฎหมายจะต้องมีองค์ประกอบด้านรูปแบบและระดับของความรุนแรง

ดังต่อไปนี้

รูปแบบ การใช้กำลังทางทหารเพื่อรุกรานรัฐอื่นเป็นกรณีเดียวที่มีระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติว่าเป็นสาเหตุที่จะทำให้รัฐซึ่งเป็นเป้าหมายสามารถใช้สิทธิป้องกันตัวได้โดยชอบธรรม และรูปแบบของการรุกรานพอจะแบ่งออกได้เป็นการรุกรานโดยตรงและโดยทางอ้อมกล่าวคือ การรุกรานโดยตรงคือการใช้ความรุนแรงต่อดินแดนของรัฐอื่น เช่น การละเมิดดินแดน การรุกรานดินแดน การยึดครองดินแดนด้วยกำลังทหารแม้จะเพียงเป็นการชั่วคราวก็ตาม การผนวกดินแดน การทิ้งระเบิด การปิดล้อมเมืองท่า นอกจากนั้นยังรวมถึงการใช้ความรุนแรงต่อกองกำลังหรือเป้าหมายทางทหารของรัฐอื่นโดยอาศัยการโจมตีทั้งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ ฯลฯ อีกด้วย

ส่วนการรุกรานโดยทางอ้อม เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งกองกำลังติดอาวุธซึ่งมิได้ประจำการหรือทหารรับจ้าง โดยรัฐหรือในนามของรัฐเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในรัฐอื่นหรือการเข้ามีส่วนร่วมอย่างมากในการกระทำเช่นนั้น ตลอดจนการอนุญาตให้มีการใช้ดินแดนของรัฐเพื่อการรุกรานรัฐอื่นด้วย เป็นต้น การแทรกแซงด้วยกำลังอาวุธหรือด้วยกำลังทางทหาร และการที่รัฐสนับสนุนคนชาติของตนให้ไปก่อการร้าย (terrorism) ในรัฐอื่น อันเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ความรุนแรงในปัจจุบันซึ่งมักจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนชาติรัฐอื่น ตลอดจนผลประโยชน์ของรัฐอื่นๆ ด้วย

ระดับของความรุนแรง ที่จะทำให้การใช้กำลังเข้าข่ายการใช้กำลังที่ผิดกฎหมายนั้น หากรัฐที่ใช้กำลังที่เป็นปัญหามีได้มีเจตนาที่จะรุกรานและมิได้เป็นการกระทำที่รุนแรงมากนักก็ไม่เป็นการใช้กำลังทางทหารที่ต้องห้ามในความหมายนี้ และเป็นเพียงเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเท่านั้น เช่น การปะทะกันเพียงเล็กน้อยตามบริเวณพรมแดน เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจผิดกันหรือเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุก็ได้

ส่วนการคุกคามเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยุ่งยากที่จะยืนยันได้อย่างปราศจากข้อโต้แย้ง เนื่องจากไม่อาจประเมินได้จากระดับความรุนแรงของการกระทำเพราะยังมิได้เกิดการใช้กำลังนั้น และการประเมินสถานการณ์ก็มักจะเป็นการใช้ดุลพินิจของรัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม โดยสามัญสำนึกและตามหลักตรรกวิทยาแล้ว การคุกคามที่ผิดกฎหมายน่าจะต้องมีลักษณะที่ค่อนข้างแน่นอนว่าจะเกิดการรุกรานขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ เช่น การเคลื่อนกองกำลังเข้าประชิดพรมแดนในลักษณะที่เป็นการเตรียมที่จะบุกโจมตี เป็นต้น และยิ่งหากมีปฏิบัติการทางทหารติดตามการคุกคามนั้นด้วย เช่น มีการยื่นคำขาดก็ย่อมเป็นการแน่ชัดว่าเป็นการคุกคามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การใช้กำลังที่ไม่ขึ้นอยู่กับความชอบธรรมของวัตถุประสงค์ กฎบัตรสหประชาชาติ ระบุกรณีที่ต้องห้ามโดยแจ้งชัดโดยถือว่าเป็นการใช้กำลังที่มีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายว่าได้แก่ การโจมตีบูรณภาพแห่งดินแดนและเอกราชทางการเมืองของรัฐ เป็นเรื่องการรุกราน

การกระทำการตอบโต้ (reprisals) ก็เป็นการกระทำซึ่งโดยปกติถือว่าเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าเป็นการกระทำอันเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศและการกระทำนั้นได้สัดส่วนกับการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว กฎหมายไม่ถือว่าการกระทำตอบโต้ต่อการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นการละเมิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่สำหรับแนวโน้มในปัจจุบันหากการกระทำตอบโต้เป็นการกระทำโดยใช้กำลังทางทหารก็ถือเป็นการใช้กำลังที่ผิดกฎหมาย

กล่าวโดยสรุปแล้ว ในปัจจุบันนี้ การใช้กำลังซึ่งแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่มีความชอบธรรม หากไม่เข้าข่ายการใช้สิทธิป้องกันตัว โดยหลักการแล้วต่างก็เป็นการกระทำที่ผิดข้อห้ามในเรื่องการใช้กำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสิ้น

การใช้กำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักการห้ามใช้กำลังทางทหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของการใช้กำลังในระดับระหว่างประเทศ

การใช้กำลังของรัฐภายในประเทศ ถึงแม้จะเป็นการใช้กำลังภายในประเทศของตนเอง หากมีการขยายขอบเขตที่กว้างขวางและความรุนแรงอย่างมากจนกลายเป็นการคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก็อาจเป็นเรื่องผิดกฎหมายในฐานการคุกคามต่อสันติภาพของภูมิภาค

กรณีที่เป็นสงครามกลางเมือง ตามหลักการห้ามแทรกแซงในกิจการภายในของกบฏประชาชนชาติ และข้อห้ามการแทรกแซงทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งข้อห้ามการให้ความสนับสนุนสงครามกลางเมืองในข้อมติของสหประชาชาติที่ 2625 ถือว่าการช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยการเข้าร่วม การให้ความช่วยเหลือหรือการปล่อยให้มีการแทรกแซง แต่การให้ความสนับสนุนรัฐบาลที่ชอบธรรมเมื่อได้รับการร้องขออย่างชัดเจนเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติจริง การอ้างว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือมักถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่ออำพรางการแทรกแซงที่น่าจะผิดกฎหมาย

ข้อยกเว้นของการห้ามใช้กำลัง โดยทฤษฎีแล้วมี 2 กรณีที่กบฏประชาชนชาติอนุญาตให้รัฐใช้กำลังได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติยังมีอยู่อีกกรณีหนึ่งซึ่งแม้จะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน แต่จากท่าทีของนานาชาติซึ่งยอมรับกันโดยปริยายทำให้พอจะสรุปได้ว่า อยู่ในข่ายข้อยกเว้นของมาตรา 2 วรรค 4 ดังจะได้ศึกษากันในรายละเอียดต่อไป

กรณีข้อยกเว้นตามกฎหมายประชาชนชาติ ข้อยกเว้นของมาตรา 2 วรรค 4 มี 2 ประการคือ

1.) **การป้องกันตัว (Self Defense)** การป้องกันตัวที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายนี้มีองค์ประกอบทางกฎหมาย รูปแบบและเงื่อนไขที่ชัดเจนซึ่งจะได้วิเคราะห์กันดังต่อไปนี้

ก. พื้นฐานทางกฎหมายและรูปแบบ สิทธิของรัฐที่จะป้องกันตนเองเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศอันเป็นที่ยอมรับกันโดยตลอดมา และตามมาตรา 51 ของกบฏประชาชนชาติ

ข. เงื่อนไขในการใช้สิทธิป้องกันตัว การใช้สิทธิป้องกันตัวนั้นจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อเป็นการกระทำเพื่อตอบโต้ต่อการรุกราน โดยมาตรการที่ใช้ตอบโต้ต้องได้สัดส่วนกับการรุกรานด้วยเท่านั้น

การใช้สิทธิป้องกันตัวด้วยกำลังอาวุธยังมีความแตกต่างจากหลัก "การช่วยเหลือตนเอง" (Self help) ด้วยการใช้อำนาจเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนด้วยตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วไม่ถือว่าเข้าข่ายข้อยกเว้นของการห้ามใช้กำลัง แต่ในทางปฏิบัติจริงรัฐที่ใช้สิทธิ

2.) **การเข้าร่วมในปฏิบัติการทางทหารของสหประชาชาติ**ตามมาตรา 2 วรรค 5 และในหมวดที่ 7 ของกบฏฯ เนื่องจากสหประชาชาติมิได้มีกองทัพส่วนตัวของตนเอง จึงต้องอาศัยกองกำลังของรัฐสมาชิก รวมตัวกันไปปฏิบัติการในนามขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งอาจมีภารกิจทางทหารหลายลักษณะ

3.) การแทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม ถึงแม้ว่าในอดีต การใช้กำลังทางทหารในลักษณะอื่นที่นอกเหนือไปจากเรื่องการป้องกันตัวจะไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมาย แต่จากข้อห้ามในมาตรา 2 วรรค 4 และการได้แย่งความชอบธรรมของการใช้วิธีการเหล่านั้นโดยรัฐต่างๆ ทำให้ในทางปฏิบัติพอจะยืนยันได้ว่า นอกจากข้อยกเว้นที่ระบุอย่างชัดเจนไว้ในกฎบัตรแล้ว ยังมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งได้กลายเป็นการใช้กำลังที่ขอบด้วยกฎหมายไปแล้วคือ การใช้กำลังเข้าแทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเพื่อคุ้มครองบุคคลที่ประสบอันตรายหรือตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายในต่างประเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

1.) ประการแรก สถานการณ์อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องใช้กำลังเข้าแทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมจะต้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่ร้ายแรงและเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ซึ่งบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรม

ยิ่งกว่านั้น ยังจะต้องมีสาเหตุอันควรเชื่อว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนั้น เป็นการกระทำของรัฐเจ้าของดินแดนนั้นเอง หรืออาจมีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างผู้ละเมิดกฎเกณฑ์กับรัฐเจ้าของดินแดนซึ่งอาจเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือจําใจ โดยปล่อยปละละเลยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ก็ได้

2.) ประการต่อมา มาตรการที่ใช้ต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำโดยไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นได้ เนื่องจากความฉุกเฉินของสถานการณ์ซึ่งความล่าช้าอาจทำให้สายเกินกว่าที่จะเยียวยาได้ และการรับข้อพิพาทโดยสันติวิธีหรือโดยทางการทูตอาจเป็นวิธีการที่สถานการณ์ไม่อำนวยหรือไม่เหมาะสมเพราะจะทำให้สายเกินแก้หรือรัฐเป้าหมายมีพฤติกรรมที่สื่อให้เห็นว่าการใช้วิธีการเช่นนั้นไม่อาจบรรลุผลสำเร็จได้

นอกจากนี้ บุคคลที่ถูกคุกคามซึ่งรัฐที่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนชาติของรัฐที่เข้ามาแทรกแซงด้วยกำลัง โดยอาจเป็นคนชาติของรัฐเจ้าของดินแดนที่เป็นเป้าหมายของการแทรกแซงเองก็ได้

3.) ประการสุดท้าย มาตรการที่ใช้ก็ต้องได้สัดส่วนกับการละเมิดกฎเกณฑ์และเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้น จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะพิจารณาปัญหาและเข้าดำเนินการ แต่หากคณะมนตรีความมั่นคงประสบอุปสรรคจากสิทธิโต้ ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการด้วยตนเองได้ หรือไม่สามารรถชี้ขาดหรือตัดสินใจในเรื่องนี้ให้ทันการได้ ปฏิบัติการใช้กำลังอาวุธเข้าแทรกแซงก็ย่อมดำเนินต่อไปได้เท่าที่จำเป็นตามสถานการณ์

หลักกฎหมาย *jus in bello*

สาระสำคัญของกฎหมายภาคสงครามในปัจจุบันถูกบัญญัติไว้ใน ออนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. 1949 ทั้ง 4 ฉบับซึ่งในทางปฏิบัติมีผลผูกพันรัฐทั้งปวงในทางระหว่างประเทศ กล่าวคือ

อนุสัญญากรุงเจนีวาฉบับที่ 1 เกี่ยวกับเงื่อนไขของผู้ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยของกองทัพในสนามรบ

อนุสัญญากรุงเจนีวาฉบับที่ 2 เกี่ยวกับเงื่อนไขของผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยและเรืออับปางของสมาชิกของกองทัพในทะเล

อนุสัญญากรุงเจนีวาฉบับที่ 3 เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อนักโทษสงคราม

อนุสัญญากรุงเจนีวาฉบับที่ 4 เกี่ยวกับการคุ้มครองพลเรือนในภาวะสงคราม

อนุสัญญากรุงเจนีวาทั้ง 4 ฉบับข้างต้น มีรัฐเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาเป็นจำนวนมากอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาส่วนใหญ่ของอนุสัญญาเหล่านี้ก็ได้รับการยอมรับกันทั่วไปว่ามีลักษณะเป็นการประกาศกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ดังนั้น กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในอนุสัญญาดังกล่าวย่อมมีผลใช้บังคับกับรัฐที่ยังไม่ได้เป็นภาคีในสนธิสัญญา แต่ก็ต้องผูกพันในฐานะที่กฎเกณฑ์มีลักษณะเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายของกรุงเฮกก็มีลักษณะทำนองเดียวกันกับกฎหมายของกรุงเจนีวา คือ อยู่ในรูปของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1907 หลายฉบับ แต่ได้รับการรับรองกันทั่วไปว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ โดยอาจจะระบุได้ ดังนี้

อนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 3 เกี่ยวกับการเริ่มความเป็นปฏิปักษ์

อนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 4 เกี่ยวกับกฎหมายและจารีตประเพณีของสงครามบนบกและภาคผนวกของอนุสัญญา : ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายและจารีตประเพณีของสงครามบนบก

อนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 5 เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประเทศและบุคคลเป็นกลางในกรณีสงครามบนบก

อนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 6 เกี่ยวกับสถานะของเรือสินค้าศัตรูเมื่อเกิดความเป็นปฏิปักษ์

อนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 7 เกี่ยวกับการแปลงเรือสินค้าเป็นเรือรบ

อนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 8 เกี่ยวกับการวางทุ่นระเบิดอัตโนมัติใต้น้ำ

อนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 9 เกี่ยวกับการโจมตีด้วยกองกำลังทางเรือในภาวะสงคราม

อนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 11 เกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการในเรื่องการใช้สิทธิในการจับในสงครามทางเรือ

อนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 13 เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประเทศเป็นกลางในสงครามทางเรือ

นอกจากนี้ยังมีพิธีสาร ค.ศ. 1977 เพิ่มเติมอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. 1949 อีก 2 ฉบับซึ่งทั้งยืนยันและพัฒนามาจากอนุสัญญากรุงเจนีวา ค.ศ. 1949 และอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1907 บางส่วนด้วย กล่าวคือ

พิธีสารวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1977 เพิ่มเติมอนุสัญญากรุงเจนีวาวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 เกี่ยวกับการคุ้มครองเหยื่อของการขัดแย้งทางทหารระหว่างประเทศ (พิธีสารฉบับที่ 1)

พิธีสารวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1977 เกี่ยวกับการคุ้มครองเหยื่อของการขัดแย้งทางทหารที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศ (พิธีสารฉบับที่ 2)

พิธีสารทั้งสองฉบับยังคงไม่ได้รับการยอมรับในลักษณะสากลกล่าวคือ ยังมีรัฐที่ไม่ได้เป็นภาคีอีกพอสมควรซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส แม้ว่าบทบัญญัติบางส่วน of พิธีสารได้รับการยอมรับว่าเป็นการประกาศจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ตัวอย่างเช่น ในกรณีสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมิได้เป็นภาคีในพิธีสารฉบับที่ 1 เช่น อิรัก และรัฐมหาอำนาจบางรัฐที่เข้าร่วมเป็นกองกำลังนานาชาติ แต่รัฐที่ร่วมเป็นพันธมิตรเหล่านี้ก็ประกาศนโยบายในการรบโดยสอดคล้องตามกฎหมายเกณฑ์ในพิธีสารโดยเฉพาะในมาตรา 48 -57 กล่าวคือ จะเน้นปฏิบัติการโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น

ยิ่งกว่านั้น ยังมีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเฉพาะของการทำสงครามและการคุ้มครองทรัพย์สินซึ่งที่สำคัญ ได้แก่

ปฏิญญาเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1868 สละสิทธิการใช้ในภาวะสงครามซึ่งวัตถุระเบิดซึ่งมีน้ำหนักต่ำกว่า 400 กรัม

ปฏิญญากรุงเฮก วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1899 เกี่ยวกับลูกปืน ดัมดัม

พิธีสารกรุงเจนีวา วันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1925 สำหรับการห้ามใช้ในสงครามซึ่งแก๊สพิษ แก๊สอื่นๆ และวิธีการทำสงครามชีวภาพอื่นๆ

บันทึกการประชุมกรุงลอนดอน วันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1936 เกี่ยวกับกฎหมายของสงครามใต้ทะเล

อนุสัญญากรุงเฮก วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1954 เพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีการขัดกันทางอาวุธ

อนุสัญญา วันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1972 ว่าด้วยการห้าม การพัฒนา การผลิตและการสะสมอาวุธชีวภาพ อาวุธที่เป็นพิษและการห้ามการทำลายล้างด้วยอาวุธเหล่านี้

อนุสัญญา วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1977 ว่าด้วยการห้ามการใช้ทางทหารหรือในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์อื่นซึ่งเทคนิคการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

อนุสัญญา วันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1980 ว่าด้วยการห้ามหรือจำกัดใช้อาวุธธรรมดาบางประเภทซึ่งอาจถือว่าก่อให้เกิดผลเสียหายที่เกินจำเป็นหรือมีผลที่ไม่เลือกปฏิบัติ

สรุป

การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ ของจักรวรรดิญี่ปุ่นต่อฝ่ายกองทัพอเมริกา ที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ มลรัฐฮาวาย โดยไม่มีการแจ้งเตือน นั้นเป็นการผิดกฎหมาย Jus in bello ตาม อนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 3 เกี่ยวกับการเริ่มความเป็นปฏิปักษ์

วิเคราะห์

นักศึกษาจำนวนหนึ่ง ไม่ได้อ่านเรื่อง Jus ad bellum กฎหมายว่าด้วยการห้ามการใช้กำลัง และเรื่อง Jus in bello กฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้กำลังโดยชอบ นั้น ว่าต้องทำอะไร การบุกโจมตี เวิร์ล ชาเบอร์ โดยไม่ได้มีการแจ้ง ถือว่าผิดหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้กำลัง

จึงแนะนำให้นักศึกษา บริหารเวลา เรียนให้รู้จริง วิเคราะห์ได้ เข้าใจ ต้องแก้เท่านั้น ก็จะช่วยให้ นักศึกษาสอบผ่านได้ด้วยดี